



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 05/2012 (19957.001606/2020-43)

Data do julgamento: 03/12/2019

Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

Acusados: ARX Capital Management Ltda.
Carlos Eduardo Teixeira Ramos
BNY Mellon Serviços Financeiros D.T.V.M.
José Carlos Lopes Xavier de Oliveira

Ementa: Irregularidades envolvendo negócios efetuados por fundos de investimentos geridos pela ARX Capital Management Ltda. Infração ao artigo 65, XV, c/c artigo 65-A, I, ambos da Instrução CVM nº 409/2004. Prática não equitativa, definida no item II, letra "d", da Instrução CVM nº 08/1979 e vedada pelo item I da mencionada Instrução. Absoluções e advertências.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, com fundamento no art. 11 da Lei nº 6.385/76, decidiu:

- **Por unanimidade:**

a) pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva da CVM no que se refere aos fatos praticados entre 2003 a 30.12.2005;

b) pela **absolução** de **BNY Mellon Serviços Financeiros D.T.V.M.** da acusação de violação ao artigo 65, XV, c/c artigo 65-A, I, ambos da Instrução CVM nº 409/2004;

c) pela **absolução** de **José Carlos Lopes Xavier de Oliveira** da acusação de violação ao artigo 65, XV, c/c artigo 65-A, I, ambos da Instrução CVM nº 409/2004.

- **Por maioria:**

a) pela condenação da **ARX Capital Management Ltda.** à penalidade de **advertência** por ausência de critério de rateio equitativo de ordens de compra e venda dentre os diversos fundos sob sua gestão no período entre 31.12.2005 e 31.12.2006, prevista no artigo 14, II, da Instrução CVM nº 306/1999 e no artigo 60, parágrafo único, da Instrução CVM nº 409/2004;

b) pela **absolvição** da **ARX Capital Management Ltda.** da acusação de infração ao artigo 65-A, I, da Instrução CVM nº 409/2004;

c) pela **absolvição** da **ARX Capital Management Ltda.** da imputação de prática não equitativa, definida no item II, letra “d”, da Instrução CVM nº 08/1979 e vedada pelo item I da mencionada Instrução;

d) pela condenação de **Carlos Eduardo Teixeira Ramos** à penalidade de **advertência** por não ter empregado o devido cuidado e diligência em promover a implantação de sistemas de controles internos que assegurassem o atendimento da regulação em vigor, especialmente no que se refere aos critérios de rateio de ordens, em violação ao artigo 14, II, da Instrução CVM nº 306/1999 e ao artigo 60, parágrafo único, c/c artigo 65-A, I, ambos da Instrução CVM nº 409/2004;

A sessão de julgamento teve início em 27 de agosto de 2019, ocasião em que o Relator, Diretor Gustavo Machado Gonzalez, votou: (i) pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva por parte da CVM no tocante aos fatos praticados entre 2003 a 2005; (ii) pela **absolvição** de **BNY Mellon Serviços Financeiros D.T.V.M.** da acusação de violação ao artigo 65, XV, c/c artigo 65-A, I, ambos da Instrução CVM nº 409/2004; (iii) pela **absolvição** de **José Carlos Lopes Xavier de Oliveira** da acusação de violação ao artigo 65, XV, c/c artigo 65-A, I, ambos da Instrução CVM nº 409/2004, (iv) pela condenação da **ARX Capital Management Ltda.** à penalidade de **advertência** por ausência de critério de rateio equitativo de ordens de compra e venda dentre os diversos fundos sob sua gestão no período entre 31.12.2005 e 31.12.2006, prevista no artigo 14, II, da Instrução CVM nº 306/1999 e no artigo 60, parágrafo único, da Instrução CVM nº 409/2004; (v) pela **absolvição** da **ARX Capital Management Ltda.** da acusação de infração ao artigo 65-A, I, da Instrução CVM nº 409/2004; (vi) pela **absolvição** da **ARX Capital Management Ltda.** da imputação de prática não equitativa, definida no item II, letra “d”, da Instrução CVM nº 08/1979 e vedada pelo item I da mencionada Instrução; e (vii) pela condenação de **Carlos Eduardo Teixeira Ramos** à penalidade de **advertência** por não ter empregado o devido cuidado e diligência em promover a implantação de sistemas de controles internos que assegurassem o atendimento da regulação em vigor, especialmente no que se refere aos critérios de rateio de ordens, em violação ao artigo 14, II, da Instrução CVM nº 306/1999 e ao artigo 60, parágrafo único, c/c artigo 65-A, I, ambos da Instrução CVM nº 409/2004. Na sequência a sessão foi suspensa em decorrência de pedido de vista realizado pelo Diretor Henrique Machado.

Presente o Procurador Federal Leonardo Montanholi.

Presente o advogado Julian Fonseca Peña Chediak, representando todos os acusados.

Presentes na sessão os Diretores Gustavo Machado Gonzalez, Carlos

Alberto Rebello Sobrinho, Flávia Sant'Anna Perlingeiro, Henrique Balduino Machado Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão de Julgamento.

Em 03 de dezembro, na continuação da Sessão de Julgamento, o Diretor Henrique Machado divergiu parcialmente do voto do Diretor Relator e votou (i) pela condenação da ARX à penalidade de R\$100.000,00 (cem mil reais) por ausência de critério de rateio equitativo de ordens de compra e venda dentre os diversos fundos sob sua gestão no período entre 31.12.2005 e 31.12.2006, prevista no artigo 14, II, da Instrução CVM nº 306/1999 e no artigo 60, parágrafo único, da Instrução CVM nº 409/2004; (ii) pela condenação de Carlos Teixeira à penalidade de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais) por não ter promovido a implantação de sistemas de controles internos que assegurassem o atendimento da regulação em vigor, especialmente no que se refere aos critérios de rateio de ordens, em violação ao artigo 14, II, da Instrução CVM nº 306/1999 e ao artigo 60, parágrafo único, c/c artigo 65-A, I, ambos da Instrução CVM nº 409/2004; e (iii) pela condenação da ARX à penalidade de R\$400.000,00 (quatrocentos mil reais) pela prática não equitativa, conforme conduta definida no item II, letra "d", da Instrução CVM nº 08/1979 e vedada pelo item I da mencionada Instrução.

A Diretora Flávia Perlingeiro acompanhou o voto do Relator, Diretor Gustavo Gonzalez, com exceção da condenação da ARX e de Carlos Teixeira à penalidade de advertência. Neste ponto, concordou com os fundamentos do Diretor Henrique Machado e acompanhou seu voto na aplicação de multas pecuniárias.

O Diretor Carlos Rebello Sobrinho e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, acompanharam integralmente o voto do Relator.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM nº 607/2019. As decisões absolutórias transitam em julgado na primeira instância.

Presente na continuação da sessão o Procurador Federal Leonardo Montanholi.

Presente na continuação da sessão o advogado Julian Fonseca Peña Chediak, representando todos os acusados.

Participaram da Continuação da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Machado Gonzalez, Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Flávia Sant'Anna Perlingeiro, Henrique Balduino Machado Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão de Julgamento.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor**, em 14/03/2020, às 21:58, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 16/03/2020, às 15:15, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 16/03/2020, às 19:23, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Usuário Externo**, em 17/03/2020, às 16:17, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Machado Gonzalez, Diretor**, em 17/03/2020, às 18:06, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0955888** e o código CRC **E2783412**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0955888** and the "Código CRC" **E2783412**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 05/2012

Reg. Col. nº 0342/2016

Acusados: ARX Capital Management Ltda.
Carlos Eduardo Teixeira Ramos
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
José Carlos Lopes Xavier de Oliveira

Assunto: Apurar eventuais irregularidades envolvendo negócios efetuados por fundos de investimentos geridos pela ARX Capital Management Ltda.

Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

RELATÓRIO

I. OBJETO

1. Trata-se de processo administrativo sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Processos Sancionadores (“SPS”) e pela Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”, e, em conjunto com SPS, “Acusação”) para apurar eventuais irregularidades envolvendo negócios efetuados por fundos de investimentos geridos pela ARX Capital Management Ltda. (“ARX” ou “Gestora”).
2. A ARX responde a duas acusações distintas, cada qual referente a um período de tempo. A primeira delas – ausência de critério de rateio equitativo de ordens de compra e venda dentre os diversos fundos sob sua gestão, em infração ao artigo 14, II, da Instrução CVM nº 306/1999 e ao artigo 60, parágrafo único, c/c artigo 65-A, I, ambos da Instrução CVM nº 409/2004 – abarca o período de 2003 a 2006. A segunda acusação é por realizar prática não equitativa no mercado de valores mobiliários (definida no item II, letra “d”, da Instrução CVM nº 08/1979 e vedada pelo item I da mencionada Instrução) e se refere apenas ao ano de 2007.
3. O diretor da ARX responsável pela atividade de administração de carteiras de valores mobiliários no período coberto pelo processo, Carlos Eduardo Teixeira Ramos (“Carlos Ramos”), foi acusado por não ter empregado o devido cuidado e diligência em promover a implantação de sistemas de controles internos que assegurassem o atendimento da regulação em



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

vigor, especialmente no que se refere aos critérios de rateio de ordens (violação ao artigo 14, II, da Instrução CVM nº 306/1999 e ao artigo 60, parágrafo único, c/c artigo 65-A, I, ambos da Instrução CVM nº 409/2004).

4. Por sua vez, BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (“BNY Mellon” ou “Administrador Fiduciário”) e o seu diretor responsável pela atividade de administração fiduciária de fundos de investimento à época, José Carlos Lopes Xavier de Oliveira (“José Carlos Lopes”), foram acusados de infringir o artigo 65, XV, c/c artigo 65-A, I, ambos da Instrução CVM nº 409/2004. Segundo a Acusação, o Administrador Fiduciário não teria observado o dever de fiscalizar a Gestora, tampouco o seu dever de diligência.

5. Já José Carlos Lopes, segundo a Acusação, não teria empregado o devido cuidado e diligência para promover a implantação de sistema de controles internos com vistas a garantir o atendimento à legislação em vigor, especialmente no que se refere aos critérios de rateio de ordens.

II. ORIGEM

6. No âmbito do seu trabalho regular de acompanhamento dos mercados futuros da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), a Gerência de Acompanhamento de Mercado 2 (GMA-2) da Superintendência de Mercados de Intermediários (SMI) da CVM identificou que, durante o ano de 2007, um dos fundos geridos pela ARX, o ARX Strike Fundo de Investimento Multimercado (“Fundo ARX Strike”), incorreu em perdas de R\$6.795.100,00 (seis milhões, setecentos e noventa e cinco mil e cem reais) em ajustes do dia com operações no mercado Futuro de Índice Bovespa. A GMA-2 apurou, ainda, que outros fundos de investimento também geridos pela ARX (“Fundos Beneficiados”)¹ realizaram, no mesmo período, operações naquele mesmo mercado e obtiveram ganhos em ajustes do dia que totalizaram R\$5.344.998,00 (cinco milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e oito reais)².

7. Tendo em vista essa divergência de resultados e considerando, ainda, que todas as operações realizadas tanto pelo Fundo ARX Strike quanto pelos Fundos Beneficiados haviam

¹ Os fundos geridos pela ARX que realizavam operações a partir da conta Ágora 17700, denominada BNY Mellon ARX Investimentos Ltda Master (“Conta Máster”), no ano de 2007 são: BNY Mellon ARX FIA; ARX Hedge FIM; ARX Plus FIM; ARX Institucional FIM; FIF Andes; BNY Mellon ARX Extra FIM; BNY Mellon ARX Long Short FIM; BNY Mellon ARX Long Short 30 FIM; Biarritz LLC; ARX Long Short 30 PF FIM; Especial II FIM; Especial I FIM (M195 FIM); Especial III FIM (M215 FIM); ARX Plus MAX FIM; Match Point Investment LLC; Match Point Investments LLC; Especial 4 FIM; e Especial 5 FIM (item 46 do Relatório de Inquérito).

² Relatório de Análise GMA-2 nº 003/2008 (fls. 6-19).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

sido intermediadas por uma única corretora, a GMA-2 verificou a existência de indícios de irregularidades em operações com contratos futuros realizadas em nome de diversos fundos de investimento geridos pela ARX e administrados pelo BNY Mellon entre janeiro e dezembro de 2007. Assim, em fevereiro de 2008, a SMI propôs a abertura de Inquérito Administrativo³ para aprofundar as investigações e apurar eventuais responsabilidades.

8. Em 08.06.2012, o Superintendente Geral determinou a instauração de processo para apurar “eventuais irregularidades envolvendo negócios efetuados por fundos de investimentos geridos pela ARX Capital Management Ltda., no mercado futuro de Ibovespa na BM&F no período de janeiro a dezembro de 2007”⁴.

III. ACUSAÇÃO

III.1. As operações realizadas por meio da conta máster

9. Inicialmente, a área técnica destacou o comando do *caput* do artigo 60 da Instrução CVM nº 409/2004, segundo o qual “as ordens de compra e venda de ativos financeiros devem sempre ser expedidas com a identificação precisa do fundo de investimento em nome do qual elas devem ser executadas.” Apontou, ainda, que quando uma mesma pessoa jurídica administrar diversos fundos, o parágrafo único daquele mesmo comando permite, “o grupamento de ordens, desde que o administrador tenha implantado sistema que possibilite o rateio, entre os fundos, das compras e vendas feitas, através de critérios equitativos e preestabelecidos, devendo o registro de tal repartição ser mantido à disposição da CVM pelo período mínimo de 5 (cinco) anos.”

10. Após trocas de comunicações entre a área técnica e a Gestora, constatou-se que, à época dos fatos analisados neste PAS, a ARX administrava diversas carteiras, incluindo parte da Clube de Investimento dos Empregados da Companhia Vale do Rio Doce (“Investvale”). Segundo a Gestora, os fundos geridos eram segregados em “famílias”, de acordo com a estratégia de investimentos que seguia. O Fundo ARX Strike era um fundo exclusivo do Investvale e integrava, junto com a carteira do referido clube, a estratégia denominada Cartinvest.

11. O gráfico abaixo, extraído do relatório da Acusação (o “Relatório de Acusação”) apresenta algumas das “famílias” de fundos geridos pela ARX existentes à época⁵:

³ Fls. 6/19.

⁴ Portaria/CVM/SGE/Nº 117 – fls. 1.

⁵ Item 31 do Relatório de Acusação.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Figura 1. Famílias de fundos geridos pela ARX

Estratégia Long Short	Estratégia Macro	Estratégia Equity Hedge	Estratégia Ações	Estratégia Cartinvest
ARX Long Short FIM	ARX Hedge FIF	ARX Extra FIF	ARX FIA	ARX Strike FIM
ARX Long Short 30 FIM	ARX Institucional FIF			+
ARX Long Short 30 PF FIM	ARX Plus FIM			Carteira própria Investvale
	ARX Plus Max FIM			

12. Ao ser questionada pela área técnica sobre o critério de rateio de ordens que adotava, a Gestora alegou que, para as famílias que continham mais de um fundo, as ordens de compra e venda “eram realizadas de forma agrupada e alocadas proporcionalmente de acordo com o respectivo patrimônio de cada uma de suas carteiras” (fl. 331). Já as ordens de compra e venda de fundos que seguiam estratégias independentes e eram os únicos de suas famílias (como, na figura acima, o Fundo ARX Strike, ARX Extra FIF e ARX FIA), “eram realizadas de maneira individualizada” (fls. 332).

13. A Acusação afirmou ter encontrado uma série de elementos indicando que as ordens dadas em nome dos fundos de diferentes famílias eram usualmente realizadas em nome de uma única conta máster e especificadas, apenas ao final do pregão. Para verificar se a sistemática de rateio definida na “Política de Alocação Justa – Fair Allocation” da ARX era efetivamente observada pela Gestora na distribuição das ordens de compra e venda de ativos realizados em nome dos fundos por ela geridos, a Acusação procedeu a uma análise das operações dos 35 fundos que operaram no mercado futuro de Índice Bovespa no ano de 2007 (fls. 359 a 364).

14. A análise foi feita a partir de uma amostra de 20 dias do ano de 2007, aleatoriamente selecionados. Após análise de todas as ordens emitidas por fundos de investimento geridos pela ARX nesses dias, a Acusação pôde constatar que 99,7% das operações realizadas nesses dias pelos Fundos Beneficiados e pelo Fundo ARX Strike foram originalmente feitas por meio da conta máster. Diante disso, a Acusação verificou que, independentemente da estratégia adotada pelo fundo, ou a qual “família de fundos” da ARX ele pertencesse, esses 19 fundos operavam habitualmente de forma agrupada, utilizando a mesma conta na corretora.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

15. Adicionalmente, a Acusação apurou que, nesse universo de ordens realizadas por meio da conta máster, 97,3% foram especificadas após às 18h00, ou seja, quando já eram conhecidos os valores dos ajustes do dia para cada negócio realizado. Além disso, a área técnica verificou que, em 11 dias ao longo de 2007:

- (i) embora o Fundo ARX Strike tenha sido o único fundo a operar, as ordens não haviam sido emitidas em seu nome, mas alocadas na conta máster e especificadas também após o término do pregão;
- (ii) o Fundo ARX Strike foi o único de 19 fundos que operou consistentemente nos dias em que a ARX obteve os maiores prejuízos, sendo que, nesses dias, houve uma concentração de operações especificadas em nome do Fundo ARX Strike;
- (iii) dos 221 pregões em que foram registradas operações dos 19 fundos, em apenas 38 dias foram registrados negócios do Fundo ARX Strike, enquanto nos 10 dias em que foram registrados os maiores ajustes negativos, o Fundo ARX Strike operou em 9 deles;
- (iv) do total de 12.224 contratos negociados pelos 19 fundos nos 10 piores dias, cerca de 65% foram registrados em nome do Fundo ARX Strike, sendo que 92,7% do prejuízo total foi destinado a ele e apenas 7,3% aos demais fundos; e
- (v) nos demais 211 pregões em que operou, a participação do Fundo ARX Strike no volume de contratos negociados foi de apenas 8%.

16. A área técnica também analisou os negócios realizados entre 2003 e 2006 por todos os fundos geridos pela ARX, tendo verificado os mesmos padrões das operações realizadas em 2007, quais sejam:

- (i) em todos esses anos, o Fundo ARX Strike apresentou o maior prejuízo acumulado, no montante de R\$22.485.228,00 (vinte e dois milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, duzentos e vinte e oito reais), decorrentes de ajustes do dia; e
- (ii) o Fundo ARX Strike foi o único fundo que apresentou prejuízos em todos os anos, tendo sempre o maior prejuízo anual em relação aos demais fundos, enquanto dois fundos apresentaram lucros recorrentes em 5 anos consecutivos e um fundo por 4 anos consecutivos.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

III.2. Análise do padrão de resultados

III.2.1. Ano de 2007

17. Com o objetivo de verificar se os prejuízos do Fundo ARX Strike decorreram de uma decisão deliberada da Gestora de especificar prioritariamente para esse fundo as operações com contratos futuros de Índice Bovespa realizadas por meio da conta máster no ano de 2007 que resultaram em ajustes do dia negativos, a Acusação realizou uma série de análises. Segundo a área técnica, tais análises foram baseadas em “modelos clássicos da teoria da probabilidade e modelos básicos de estatística descritiva”, de modo que “sua utilização nesta investigação teve apenas como objetivo fornecer um parâmetro de comparação e servir como mais um instrumento de análise”. Os resultados das referidas análises podem ser, assim, resumidos:

- (i) **Análise 1: Soma de resultados de ajustes do dia.** Segundo a Acusação, dos 19 fundos analisados, apenas dois apresentaram resultado negativo em ajustes do dia: o ARX FIA e o Fundo ARX Strike, sendo que o resultado negativo alcançado pelo Fundo ARX Strike supera em 13 vezes o prejuízo do ARX FIA.
- (ii) **Análise 2: Balanceamento entre operações com ajuste do dia positivos e negativos.** Apontou a Acusação que das 687 operações executadas no ano de 2007 em nome do Fundo ARX Strike, 491 (71%) tiveram ajustes do dia negativo e 196 (29%) tiveram ajustes positivos. Para testar a verossimilhança de tais resultados, a Acusação realizou uma análise probabilística, baseada nas seguintes premissas: (a) a probabilidade de ocorrência de ajuste negativo em cada operação é de 50%; e (b) os eventos (resultado positivo versus resultado negativo) são independentes. Segundo o cálculo da Acusação, a probabilidade de o Fundo obter os resultados que teve seria de 1 em 47 octilhões (47.000.000.000.000.000.000.000.000.000).
- (iii) **Análise 3: Operações do Fundo ARX Strike nos 10 dias de maior prejuízo da conta máster.** Segundo a Acusação, dos 221 pregões do ano de 2007 em que foram registradas operações dos 19 fundos, em apenas 38 dias foram registrados negócios do Fundo ARX Strike. No entanto, nos 10 dias de maior prejuízo da conta máster, o Fundo ARX Strike operou em 9 deles. Segundo os cálculos da área técnica, a probabilidade de tal evento ocorrer seria de 1 em 2.055.587.
- (iv) **Análise 4: Distribuição dos resultados entre os fundos dentro dos 10 dias de maior prejuízo da conta máster.** A acusação apontou que, do total de 12.224 contratos negociados pelos 19 fundos analisados e que geraram prejuízos em ajustes do dia, cerca



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

de 65% deles foram registrados em nome do Fundo ARX Strike, representando 92,7% do prejuízo total. Prosseguiu indicando que, nesses 10 dias, em 7 dos 9 dias em que o Fundo ARX Strike operou, a especificação de 100% dos contratos com ajuste do dia negativo recaiu sobre o fundo.

(v) **Análise 5: Comparativo do ajuste do dia por contrato.** Na sequência, analisou-se a média da razão, por operação, entre os ajustes do dia e o número de contratos negociados, para verificar se, eventualmente, as operações do Fundo ARX Strike eram discrepantes em relação às de outros fundos. Segundo a área técnica, os resultados, detalhados no Apêndice 5 do Relatório da Comissão de Inquérito, revelaram que o Fundo ARX Strike teve um ajuste do dia por contrato muito pior do que os demais fundos.

(vi) **Análise 6: Comparativo diário dos ajustes do dia de todos os fundos.** O sexto exame se baseou na dispersão dos resultados dos ajustes do dia obtidos pelos 19 fundos ao longo do ano de 2007. Dessa análise a Acusação ressaltou que: (a) todos os 11 piores ajustes do dia foram do Fundo ARX Strike; (b) dos 15 melhores ajustes do dia, apenas 1 foi do Fundo ARX Strike; e (c) dos 38 dias em que o fundo operou, em 25 deles houve ajustes do dia negativos.

18. Segundo a Acusação, “as análises para o ano de 2007 revelaram um padrão muito nítido de concentração das operações com piores resultados em ajustes do dia no comitente ARX Strike. Os resultados apresentados, em conjunto com o fato de as especificações de comitentes finais serem realizadas quando já eram conhecidos os ajustes do dia de cada negócio, indicam, fortemente, que o ARX Strike funcionava como verdadeiro ‘colchão de prejuízos’ nesse tipo específico de operação”.

III.2.2. Anos de 2003 a 2006

19. A Acusação realizou, ainda, análises estatísticas para operações realizadas entre 2003 a 2006. Ao final, entendeu que, também no período entre 2003 e 2005, a análise comparativa dos ajustes do dia de todos os fundos geridos pela ARX evidenciaria uma incontestável e nítida concentração dos piores resultados para o Fundo ARX Strike⁶. Com relação ao ano de 2006, ainda que a Acusação tenha identificado o mesmo padrão de ajustes do dia negativos para o fundo no mercado futuro de Índice Bovespa, verificou que não era tão contundente quanto nos anos anteriores.

⁶ Itens 81-95 do Relatório de Acusação (Fls. 1.704-1.708).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

III.3. Conclusões da Acusação

III.3.1.ARX

III.3.1.1. Período de 2003 a 2006: Inexistência de um sistema de rateio de ordens equitativo

20. Segundo a Acusação, o padrão de conduta da ARX no período entre 2003 e 2006 revelaria a absoluta inexistência de um sistema de rateio de ordens de negociação por critérios equitativos e preestabelecidos, tendo em vista que as ordens eram sempre emitidas em nome da conta máster, e a identificação de seus comitentes finais era realizada após o fechamento do pregão. De acordo com a Acusação, não seria razoável que o Fundo ARX Strike tivesse concentrado o maior prejuízo anual durante 5 anos. Na visão da Acusação, tampouco seria verossímil que essa discrepância nos resultados dos fundos geridos pela ARX decorresse unicamente da estratégia de investimentos adotada por cada um deles, pois, conforme pôde verificar, os outros fundos geridos pela Gestora obtiveram sucessivos ganhos operando no mesmo segmento de mercado, com o mesmo ativo e nos mesmos períodos.

21. Em resposta a ofício, a Gestora esclareceu que “somente fundos devidamente classificados dentro de uma mesma família e previamente informados ao departamento de *Compliance* poderão ter suas ordens realizadas agrupadamente.” Para a Acusação, contudo, esse argumento não se sustentaria diante do conjunto de provas e análises das operações do fundo no período de 2003 a 2006. De acordo com o que restou apurado, as ordens de negociação eram sempre emitidas em nome de uma conta máster e, somente ao final do dia, era realizada a identificação dos comitentes finais.

22. Segundo a Acusação, apesar de a ARX afirmar que, desde 2004, havia implantado um sistema interno automatizado para rateio proporcional de ordens entre fundos de uma mesma “família”, as provas dos autos demonstrariam que, na prática, esse sistema não havia se mostrado hábil a garantir a equidade na distribuição de ordens. Na visão da Acusação, isso ficaria evidente na gestão do Fundo ARX Strike, que pertence à “família” Cartinvest formada apenas pelo Fundo ARX Strike e pela carteira da Investvale. Conforme apurado pela área técnica, apesar de essa “família” possuir uma estratégia específica, ela teve suas ordens realizadas por intermédio de uma mesma corretora e por meio da mesma conta máster que os demais fundos geridos pela ARX.

23. Ainda de acordo com a Acusação, “não basta a mera formalização de um sistema que, teoricamente, garanta o rateio equânime de ordens agrupadas entre os diversos fundos geridos



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

por uma mesma entidade, sendo imprescindível a adoção de controles internos que assegurem a efetividade desse sistema”⁷.

24. Dessa forma, a Acusação entendeu que a ARX, na qualidade de Gestora do Fundo ARX Strike e dos Fundos Beneficiados, e seu diretor responsável à época, Carlos Ramos, não teriam adotado critério de rateio equitativo de ordens de compra e venda entre os diversos fundos sob sua gestão, em infração às disposições contidas no artigo 14, II, da Instrução CVM nº 306/1999.

25. Para a área técnica, a inexistência desses controles sobre a implementação de critérios equitativos e preestabelecidos para o rateio de ordens agrupadas permitiu que os Fundos Beneficiados lucrassem em detrimento do Fundo ARX Strike. Assim, devido à falha no dever de diligência verificada por essa conduta, a ARX e Carlos Ramos são também acusados por violação aos artigos 60, parágrafo único, c/c artigo 65-A, I, da Instrução CVM nº 409/2004.

III.3.1.2. 2007: Direcionamento de ordens pela ARX - Prática não equitativa

26. Segundo a Acusação, diferentemente dos anos de 2003 a 2006, a concentração dos prejuízos da conta máster no Fundo ARX Strike durante o ano de 2007 não teria decorrido da mera ausência de um sistema eficiente que garantisse a distribuição equânime das ordens executadas, mas sim do direcionamento **proposital** desses prejuízos ao Fundo ARX Strike.

27. Segundo a área técnica, a Gestora valia-se da prerrogativa do uso da conta máster e da identificação do beneficiário final de cada operação após o fechamento do pregão, de modo que o Fundo ARX Strike teria se tornado um verdadeiro “seguro” das operações dos demais fundos geridos pela ARX.

28. Nesse sentido, a Acusação trouxe os seguintes elementos:

“(a) a despeito de possuir estratégia única e não integrar nenhuma das famílias de fundos geridos pela ARX Capital, as ordens para o ARX Strike nunca eram emitidas já com a identificação precisa do Fundo, mas sim em nome de uma Conta Master;

(b) todas as operações eram intermediadas por uma única instituição, a Corretora [...];

(c) de forma sistemática, as especificações das ordens emitidas ao longo do dia pela ARX Capital em nome dos fundos sob sua gestão eram feitas não no transcorrer do pregão, mas somente após o seu encerramento, momento em que já eram conhecidos os resultados dos ajustes do dia;

⁷ Item 146 do Relatório de Inquérito.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

(d) a utilização de apenas uma Conta (Master) e a possibilidade de especificação somente ao final do dia serviram de instrumento de manobra ímpar à gestora, permitindo, p.ex., que nos 10 dias em que se verificaram os maiores prejuízos em ajustes do dia no mercado futuro de Ibovespa, em 9 deles o ARX Strike aparecesse operando e tivesse uma concentração de especificações em sua conta, o que, do ponto de vista estatístico, se revela uma distorção bastante relevante (...);

(e) desses 9 dias acima referidos, em 7 houve a especificação de 100% dos contratos em nome do ARX Strike, sendo que em 2 dias os prejuízos do fundo superaram os prejuízos da Conta Master, em razão de todos os ajustes positivos terem sido direcionados para outros fundos;

(f) essa grande margem de manobra da gestora também possibilitou que, do total de 12.224 contratos negociados por 19 fundos e que geraram resultados negativos em ajustes do dia, fosse feita a alocação de 65% para o Fundo, o que representava 92,7% do prejuízo total. Em contrapartida, para os outros 28 pregões em que o Fundo operou em 2007, sua participação em volume de contratos girou em torno de apenas 8% (...);

(g) foi também observado que, de 1.579 resultados diários por fundo, o ARX Strike responde por apenas 38. Porém, não apenas como demonstração, mas também como consequência dessa seleção dos piores resultados, o Fundo concentrou todos os 11 piores resultados em ajustes do dia. Por outro lado, dos 15 melhores resultados, apenas um foi a ele destinado (...);

(h) os testes realizados com as operações no mercado futuro de Índice Bovespa pelo ARX Strike revelam que a quantidade de ajustes do dia negativos por ele acumulada é insustentável sob o aspecto probabilístico, não decorrendo de outro fator que não a proposital alocação irregular de negócios entre os fundos geridos pela ARX Capital (...);

(i) além da anormalidade na quantidade de contratos com ajustes do dia negativos, verificou-se, ainda, que estes contratos apresentaram prejuízos relativos maiores do que aqueles atribuídos aos demais fundos analisados (...); e

(j) a despeito da alegação recorrente de que as ordens para o ARX Strike eram individuais, comprovou-se que, contrariamente, e em que pese possuir estratégia única, suas ordens também eram transmitidas de forma agrupada (...).”⁸

29. De acordo com a Acusação, tais elementos evidenciariam, de forma contundente, as discrepâncias nos resultados experimentados pelo Fundo ARX Strike, com um padrão nítido de concentração dos piores resultados em ajustes do dia nas operações realizadas no mercado futuro de Índice Bovespa. Para a Acusação, esses ajustes não teriam decorrido das forças naturais do

⁸ Item 158 do Relatório de Acusação.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

mercado, mas sim da atuação ilícita da Gestora que direcionou ao Fundo ARX Strike os piores resultados, ao passo que direcionou os melhores resultados para os Fundos Beneficiados.

30. Segundo a Acusação, o motivo para o direcionamento das perdas do dia ao Fundo ARX Strike, em benefício dos demais fundos, seria o fato de que a ARX cobrava diferentes taxas de *performance* entre eles. Com efeito, a Gestora cobrava 10% de taxa de *performance* do Fundo ARX Strike e 20% dos demais fundos, o que, aos olhos da Acusação, seria motivo suficiente para direcionar as operações com resultados menos vantajosos para o único fundo com taxa de *performance* inferior, garantindo à ARX maiores retornos.

31. A Acusação ressaltou, ainda, que, embora não houvesse sido identificado um beneficiário específico dessas operações, apurou-se que, em grande parte, os demais fundos geridos pela ARX – em especial os fundos abertos e, portanto, com um número expressivo de cotistas – obtiveram lucros na proporção inversa dos prejuízos sofridos pelo Fundo ARX Strike.

32. Dessa forma, essas “operações de seguro” realizadas pela ARX seriam suficientes para comprovar a ocorrência de prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, conforme definido pelo item II, alínea “d”, e vedado pelo item I da Instrução CVM nº 08/1979. Por outro lado, a Acusação concluiu não haver provas de que o diretor responsável ou o Administrador Fiduciário tivessem participado da realização da prática não equitativa.

III.3.2. BNY Mellon e seu diretor responsável

33. Segundo a Acusação, o Administrador Fiduciário teria confessado não ter controles sobre os critérios de rateio utilizados pelos gestores no grupamento de ordens de negociação de ativos, uma vez que entendia se tratar de atribuição exclusiva dos gestores.

34. Na visão da Acusação, contudo, a terceirização, pela administradora fiduciária, de determinados serviços relacionados direta ou indiretamente à manutenção e funcionamento dos fundos de investimento, não a desobrigaria de verificar a sua conformidade com a legislação em vigor, o regulamento do fundo e, em especial, os interesses dos cotistas. Nesse sentido, a Instrução CVM nº 409/2004, em seu artigo 65, XV, enfatizaria o dever dos administradores fiduciários de supervisionar os serviços prestados por terceiros contratados pelo fundo.

35. Assim, partindo do pressuposto de que **(i)** os prejuízos suportados pelo Fundo ARX Strike em ajustes do dia com operações no mercado futuro de Índice Bovespa teriam decorrido não de infortúnios ou erros de estratégias de investimento, mas sim da ausência de um sistema que possibilitasse o rateio equitativo de ordens de compra e venda de ativos entre os diversos



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

fundos, nos anos de 2003 a 2006; e **(ii)** de uma verdadeira prática não equitativa no mercado de valores mobiliários no ano de 2007, a Acusação concluiu que o BNY Mellon, na qualidade de administradora do Fundo ARX Strike deveria responder no âmbito de suas respectivas atribuições, por seus próprios atos e omissões.

36. Diante desse quadro, o BNY Mellon e seu diretor responsável à época dos fatos, José Carlos Lopes, foram acusados de violar os artigos 65, XV, e 65-A, I, da Instrução CVM nº 409/2004, os quais impõem, respectivamente, o dever de fiscalização dos serviços terceirizados e o dever de diligência na administração de fundos de investimento.

IV. DEFESA

37. Em 13.02.2013, os quatro acusados apresentaram defesa conjunta, que pode ser assim resumida:⁹

IV.1. Preliminar: Prescrição

38. Preliminarmente, os Acusados apontaram a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, conforme previsto no artigo 1º, *caput*, da Lei nº 9.873/1999. Isso porque, segundo a defesa, apesar de trazidos no Relatório de Inquérito, parte dos fatos tidos como irregulares, ocorridos no período de 2003 a 2006, não teriam sido investigados na apuração realizada pela GMA-2 – que teria identificado a ocorrência de perdas no Fundo ARX Strike “advindas de ajustes do dia com operações no mercado futuro de Índice Bovespa, no ano de 2007” (fls. 1.683).

39. Dessa forma, as análises conduzidas pela SPS e pela PFE – que foram os responsáveis pela inclusão dos fatos ocorridos nos anos de 2003 a 2006 no âmbito desta investigação – somente se iniciaram em 18.06.2012, quando instaurado o inquérito administrativo que deu origem ao presente processo.

IV.2. Análise da estratégia da Cartinvest

IV.2.1. Considerações gerais

40. Em seguida, a defesa teceu algumas críticas à Acusação por ter analisado o Fundo ARX Strike de forma isolada, ignorando o fato de que o referido fundo exclusivo integrava a carteira denominada Cartinvest.

41. Conforme explicado pela defesa, em 2007, a Cartinvest era composta basicamente por ações à vista negociadas na BM&FBOVESPA, pelas cotas do Fundo ARX Strike, além de

⁹ Fls. 1.784/1.853



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

alguns proventos e disponibilidades de caixa. O Fundo ARX Strike – criado antes de a própria gestão da Cartinvest passar a ser realizada pela ARX – funcionava como veículo de investimento da Cartinvest para **(i)** gestão de liquidez para carteira, com o intuito de manter o caixa da Cartinvest investido e disponível para o atendimento de pedidos de resgates; e **(ii)** gestão da exposição líquida em renda variável da carteira da Cartinvest como um todo.

42. A Cartinvest seria, portanto, uma estratégia de ações direcional, que poderia utilizar parcela de sua carteira para aproveitar as oscilações do mercado de renda variável. Assim, no âmbito da função descrita no item **(ii)** acima, os contratos de Índice Ibovespa futuro, constantes da carteira do Fundo ARX Strike, serviam para auxiliar na execução da estratégia definida no horizonte de médio prazo, de forma a ajustar a exposição da Cartinvest ao mercado de renda variável de maneira ágil e efetiva, em função da grande liquidez dos contratos de índice futuro no mercado brasileiro e de seu reduzido custo transacional.

43. Diante de tal contexto, a defesa ponderou que os ajustes ocorridos no Fundo ARX Strike deveriam ser analisados em conjunto com as posições no mercado à vista da Cartinvest. Afinal de contas, na sua visão, uma análise puramente voltada para o mercado de derivativos não refletiria a estratégia de valor relativo adotada pela carteira como um todo, sob pena de se distorcer a conclusão sobre o resultado efetivo dos negócios objeto deste processo. Isso porque, conforme argumentou, a posição em derivativos poderia funcionar como contraponto (ou mesmo *hedge*) das posições à vista.

44. Com o intuito de reforçar sua tese argumentativa, a defesa apresentou uma simulação de qual teria sido a rentabilidade da Cartinvest em 2007, caso a referida carteira não tivesse ajustado sua exposição em ações e derivativos naquele ano – considerando que o Fundo ARX Strike servia, sobretudo, como veículo de ajuste de exposição em bolsa da Cartinvest. Segundo a defesa, caso a carteira do Cartinvest tivesse se mantido constante durante todo o ano, sem qualquer atuação no mercado de derivativos (o que era feito através do Fundo ARX Strike) e/ou atuação no mercado à vista (o que era feito tanto pela Cartinvest quanto pelo Fundo ARX Strike), a rentabilidade teórica da Cartinvest teria sido de 28,10%. Dado que a rentabilidade real da Cartinvest, no mesmo período, foi de 38,67%, a defesa concluiu que a estratégia com ações e índices, operada em grande medida por meio do Fundo ARX Strike, agregou valor à Cartinvest, gerando uma rentabilidade adicional de 10,57% ao Investvale.

45. Analisando o Fundo ARX Strike de forma isolada, a defesa apontou que, com exceção do ano de 2007, a rentabilidade do referido fundo sempre esteve acima do CDI. Já com relação ao ano de 2007, a defesa sustentou que, embora a rentabilidade isolada do Fundo ARX Strike



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

tivesse sido negativa, o fundo, por si só, teria gerado incremento patrimonial de mais de R\$7 milhões ao Investvale. Assim, ao passo que o fundo havia tido rentabilidade positiva nos períodos em que o seu patrimônio líquido estava maior, teve perdas em períodos em que o patrimônio líquido do Fundo ARX Strike era menor. Para a defesa, “isto denota, no mínimo, a habilidade da gestora de aumentar e diminuir o patrimônio líquido do ARX Strike em períodos de ganho e de perda.”¹⁰

IV.2.2. Análise dos pregões em que o Fundo ARX Strike operou

46. A defesa trouxe uma análise dos 37 pregões em que o Fundo ARX Strike operou com futuros de Índice Bovespa durante o ano de 2007. A tabela abaixo, produzida pela defesa, resume a motivação da negociação realizada em cada um dos dias:

Motivação	Nº dias	Ajuste
Aumento/ redação da exposição em bolsa	21	(4.124.810,00)
Outros	1	(6.200,00)
Rolagem	4	56.090,00
Trade	3	(1.926.150,00)
Troca de índice por ação	8	(794.030,00)
Total	37	(6.795.100,00)

47. A defesa argumentou que deveriam ser, de plano, desconsiderados **(i)** os quatro pregões em que ocorreu a rolagem¹¹ da posição de índice por contratos mais longos nos quais não houve exposição direcional; e **(ii)** os oito em que a operação foi de troca da exposição de ações da Cartinvest por posições em índice (com exposição final mantida ao fator de risco bolsa).

48. Com relação aos 25 pregões remanescentes, a defesa apontou que: **(i)** em 1 deles a operação teria sido um *day-trade* com ajuste positivo; **(ii)** em 2 deles teria ocorrido 1 operação específica de índice, com ajuste negativo no dia, mas com retorno positivo em dias subsequentes; **(iii)** em 1 deles a posição teria sido irrelevante, representando menos de 0,10% do fundo e gerando ajuste negativo irrisório de R\$6.200,00; **(iv)** em 9 deles teria havido aumento de

¹⁰ Item 127 da defesa.

¹¹ Trata-se de negócio realizado no mercado de derivativos com o simples objetivo de estender o prazo de duração de uma estratégia previamente implementada, na medida em que contratos de futuro de Índice Bovespa apresentam vencimentos bimestrais, de modo que a manutenção de uma posição requer uma nova operação de exposição equivalente. Nesse sentido, destacam que não seria possível direcionar esses ajustes negativos a outra carteira que não a do próprio Fundo ARX Strike, sendo nela e, somente nela, que se encontravam as posições originais que foram mantidas por meio de tais negócios.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

posições com a bolsa caindo em média 1,54%; e (v) em 12 deles teria havido redução de posições com a bolsa subindo em média 0,70%.

49. Prosseguiu a defesa argumentando que a Cartinvest usava uma estratégia contra cíclica ou de antecipação de trajetória, ou seja, comprava em momentos em que o mercado estava caindo e vendia quando ocorria o contrário. Tratar-se-ia de estratégia que poderia resultar em prejuízos no curto prazo na busca de bons resultados no longo prazo.

50. Segundo a defesa, o fato de o Cartinvest utilizar uma estratégia contra cíclica invalidaria uma das premissas da acusação para os seus experimentos estatísticos: o de que a chance de o ajuste do dia ser positivo ou negativo seria de 50%. Segundo a defesa, isso não seria verdade, por exemplo, em situações em que se adquira determinado contrato em dia de forte volatilidade para baixo, uma vez que “difícilmente o mercado muda de tendência ao longo de um único dia, mas, ao contrário, tende a perdurar na mesma direção (persistência da direção), de modo que a probabilidade de que o mercado continue caindo é muito maior do que 50%”.

IV.2.3. Parecer Estatístico

51. A defesa apresentou, ainda, parecer do professor Vinicius Carrasco, Ph.D., e de Gustavo P. G. Joaquim, revisando as análises contidas no Relatório e os diversos argumentos de ordem estatística trazidos no âmbito do presente processo (“Parecer Estatístico”)¹², que pode ser assim resumido.

- (i) **Análise 1: Soma de resultados de ajustes do dia.** Os pareceristas alegaram que a Acusação teria ignorado três pontos relevantes:
- a. Em primeiro lugar, a análise deveria ter considerado os mandatos dos fundos. Era esperado que o número de perdas guardasse relação com o número de operações, razão pela qual seria mais correto considerar perda por operação. Indo para o caso concreto, os pareceristas indicam que, em 2007, o número de operações com futuros de Índice Bovespa realizadas pelo Fundo ARX Strike foi 7,71 vezes maior do que o número de operações realizadas pelo ARX FIA naquele período. Caso as perdas de ambos os fundos fossem ajustadas em razão do número de negócios com futuros de Índice Bovespa por eles realizados, a diferença de perdas se reduziria a 1,81 vezes.
 - b. Em segundo lugar, a análise deveria considerar o tamanho do patrimônio líquido dos fundos e medir as perdas na forma de retornos, inclusive por ser essa a forma pela qual as

¹² Fls. 1859/1901.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

perdas importarão para os fundos no momento de cobrança da taxa de performance. Fazendo esse ajuste, a perda do Fundo ARX Strike com operações de índice passaria a ser 7,7 vezes maior do que a do ARX FIA, o que guardaria semelhança com a diferença do número de operações entre os dois fundos.

- c. Em terceiro lugar, os retornos deveriam ser ajustados por alguma medida de risco. Os pareceristas calcularam então a perda em proporção ao PL dos fundos corrigida por risco e concluíram que as perdas do ARX FIA seriam, nessa perspectiva, maiores do que as do Fundo ARX Strike.

(ii) *Análise 2: Balanceamento entre operações com ajuste do dia positivos e negativos.* O parecer apontou uma série de equívocos na metodologia empregada pela Acusação:

- a. A Acusação teria utilizado, de forma indevida, a premissa de que a ocorrência de ajustes negativos seria independente entre os eventos.
 - i. No entanto, o Fundo ARX Strike fez, em média, 18,5 operações em cada um dos dias em que negociou índices futuros em 2007. Segundo os pareceristas, ao contrário do que aponta a Acusação, nessa situação, a possibilidade de as perdas em operações ocorridas em um mesmo dia serem independentes seria praticamente nula. Analisando os 37 pregões em que o Fundo ARX Strike operou com futuros de índice durante o ano de 2007, os pareceristas verificaram que em 76% dos dias, ao menos 90% dos contratos negociados pelo referido fundo tiveram o mesmo sinal de ajuste. Se as perdas fossem, de fato, independentes, a proporção de dias com ajustes com o mesmo sinal seria de 0,0145% e não 76%.
 - ii. Diante desse quadro, os pareceristas sustentaram que o mais adequado seria considerar o resultado de dias e não de operações. Desse modo, ainda assumindo que a chance de perda seria de 50%, a probabilidade de pelo menos 27 dias com ajustes negativos em 37 seria de 0,38% (ou 1 em 262) e não o um sobre quarenta e sete oitilhões apontado pela Acusação.
 - iii. Na sequência, os pareceristas fizeram uma série de outros testes, apontando que os resultados corroboravam as conclusões acima.
- b. A Acusação teria utilizado, de forma indevida, a premissa de que a probabilidade de ajuste negativos por operação seria de 50%.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- i. Nesse ponto, os pareceristas argumentaram que a probabilidade de perda associada a ajuste seria afetada pela estratégia de gestão. Assim, destacaram que quando o gestor trabalha com uma estratégia contra cíclica, ele se sujeitaria a uma probabilidade de ajuste negativo superior a 50%.
 - ii. Os pareceristas indicaram, então, que a variação da probabilidade alteraria de forma significativa o resultado. Caso a probabilidade de perda fosse de 60% (ao invés de 50%), a probabilidade de pelo menos 27 dias com ajustes negativos em 37 subiria de 0,38 para 7,22. Se fosse 80%, para 89,54%.
- (iii) *Análises 3 e 4: Operações do Fundo ARX Strike nos 10 dias de maior prejuízo da conta máster/ Distribuição dos resultados entre os fundos dentro dos 10 dias de maior prejuízo da conta máster.*** Os pareceristas apontam algumas ressalvas em relação aos cálculos feitos pela Acusação:
- a. Em primeiro lugar, apontaram que o percentual de participação do Fundo ARX Strike nos dias de maior prejuízo da conta máster se reduziria significativamente na medida em que se aumentaria o período analisado. Considerando os conjuntos de 15, 20 e 25 piores dias da conta máster em 2007, seria possível verificar que a participação do Fundo ARX Strike cairia para 85%, 75% e 60%.
 - b. Os pareceristas apontaram, então, que a análise da acusação partiria de certas premissas, incluindo a de que a probabilidade de operar em quaisquer dias seria a mesma. Em decorrência disso, os pareceristas fizeram testes que indicaram que a probabilidade de o Fundo ARX Strike operar era mais alta em dias de maior volatilidade. Na sequência, repetiram o mesmo teste para os demais fundos geridos pela ARX e não identificaram, para esses veículos, a relação entre a decisão de operar e a volatilidade.
- (iv) *Análises 5 e 6: Comparativo do ajuste do dia por contrato/ Comparativo diário dos ajustes do dia de todos os fundos.*** Novamente, os pareceristas analisaram as premissas empregadas pela Acusação. Ressaltaram, nesse ponto, que a comparação proposta pela Acusação somente seria clara se todos os fundos da amostra tivessem o mesmo processo gerador de dados, isto é, caso gerassem ajustes diários de acordo com a mesma regra probabilística. Para os pareceristas, os resultados encontrados pela acusação seriam esperados, considerando a estratégia diferenciada do Fundo ARX Strike. Para os pareceristas, qualquer comparação entre os fundos que não considere “todas as suas



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

diferenças em termos de mandato, estratégia, tamanho e risco fornece resultados de pouca verossimilhança”.

52. Após analisar criticamente as análises feitas pela Acusação, os pareceristas se dedicaram a estimar a probabilidade relevante de ajuste negativo para o Fundo ARX Strike em 2007. Usando os dados de 2000 a 2014 do índice futuro, os pareceristas estimaram que a probabilidade de ajuste negativo em uma estratégia contra cíclica nos dias 50% mais voláteis seria de 72,2%. Concluíram, assim, que “[p]onderando esse número (72,2%) pelo número de vezes que o ARX Strike operou em dias voláteis em 2007, tempos que a probabilidade de ajuste negativo a ser observada em qualquer dia é de 62,2% das vezes”.

53. Diante disso, os pareceristas refizeram os cálculos feitos anteriormente, utilizando a nova probabilidade e desconsiderando as operações de rolagem e as operações combinadas com ações e concluíram que “a probabilidade estimada de observar o que se fato aconteceu é de 13,7%”¹³.

54. Com relação à amostra, os pareceristas apontaram que o Fundo ARX Strike obteve ajustes positivos em 10 dos 37 dias em que negociou futuros de Índice Bovespa no ano de 2007. Considerando esse universo, os pareceristas calcularam que a probabilidade de apenas um desses 10 dias ter sido pinçado dentre os 20 selecionados aleatoriamente pela Acusação seria de, aproximadamente, 0,145%.

55. Transcrevo a conclusão do sumário executivo do Parecer Estatístico:

“As seções anteriores nos permitem concluir que as análises feitas no PAS CVM 05/2012 apresentam falhas metodológicas que fazem com que os resultados obtidos sejam pouco precisos e verossímeis. Em primeiro lugar, conclui-se que a seleção da amostra feita pelo PAS CVM 05/2012 foi muito desfavorável por escolher 19 dias em que o ARX Strike teve ajustes do dia negativos. A probabilidade de que isso ocorra é de 0.145%. Adicionalmente, mostrou-se que a Análise 1 ignora questões básicas como o tamanho dos fundos, o número de operações e o risco de cada estratégia. Fazendo essas considerações, os resultados se alteram drasticamente e o ARX Strike não chama mais atenção por conta dos ajustes do dia. A Análise 2 tampouco se sustenta, pois tanto a hipótese de independência entre eventos como a hipótese de 50% de probabilidade de ajuste negativo não são verificadas na prática. Assim como com a Análise 2, foi possível mostrar que as hipóteses implícitas nas Análises 3 e 4 não são corroboradas pelos dados e que era esperado observar o padrão de comportamento do ARX Strike. Finalmente, argumentamos que as análises 5 e 6 tratam os fundos como semelhantes, quando na verdade são diferentes em sua

¹³ Itens 24 e 25 do Parecer Estatístico.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

essência. Isso faz com que os resultados apresentados no PAS CVM 05/2012 sejam pouco verossímeis.”

IV.3. A suposta ausência de segregação das ordens do Fundo ARX Strike

56. Segundo a defesa, ao contrário do que alegou a Acusação, a ARX sempre transmitiu as ordens do Fundo ARX Strike de forma independente.

57. A defesa confirmou que a ARX concentrava as posições dos fundos que geria e que operava índices futuros em uma conta máster. Tal prática buscava maior eficiência operacional, ao reduzir os custos de corretagem – o intermediário, no caso, era um *discount broker* – e centralizar a liquidação, facilitando a centralização das margens.

58. A ARX argumentou, ainda, que as ordens dadas para determinada “família” de fundos eram sempre proporcionalmente rateadas. Já as ordens dadas para fundos que não pertenciam a nenhuma família – como é o caso do Fundo ARX Strike – seriam sempre emitidas e registradas em nome desse fundo e integralmente alocadas a ele. Ou seja, segundo a Gestora, jamais haveria rateio de ordens entre fundos de diferentes “famílias”.

59. A defesa apontou que o fato de a Gestora utilizar a conta máster, inclusive, para operações que não seriam rateadas posteriormente, não indicaria qualquer irregularidade. Segundo a defesa, qualquer ordem transmitida através da conta máster era anteriormente registrada em um sistema interno da ARX, baseado em planilhas de Excel disponíveis de forma transparente em um diretório público para todos os gestores das famílias de fundos, o *middle office* e o *back office* e os diretores de risco e de *compliance*. Desse modo, para a alocação das ordens ao Fundo ARX Strike a partir da conta máster, bastava que se olhasse para as planilhas de Excel públicas nas quais as ordens em seu nome haviam sido previamente registradas pelo gestor responsável.

60. A defesa assinalou, ainda, que a suposta ausência do critério de rateio de ordens não permitiria presumir a realização de prática não equitativa, que, assim como as demais infrações previstas pela Instrução CVM nº 08/1979, requereria a realização de uma conduta dolosa por parte do acusado.

IV.4. Motivação inverossímil (1): a relevância do Cartinvest para a ARX

61. A defesa apresentou uma série de argumentos com o objetivo de demonstrar que a tese da Acusação no sentido de que o Fundo ARX Strike funcionava como um “colchão de prejuízos” nas operações com ajustes diários não é verossímil.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

62. Apontou, em primeiro lugar, que, desde 2001, a Cartinvest – incluindo as operações do Fundo ARX Strike – vinha apresentando desempenho consideravelmente positivo, com relevante alta se comparado ao Ibovespa, índice de referência (*benchmark*) para estratégias com ações. Especificamente no ano de 2007, o Cartinvest teve o melhor desempenho dentre as carteiras administradas pela ARX (38,7%). Naquele ano, o Patrimônio Líquido médio da Cartinvest era o segundo maior sob gestão da ARX, representando cerca de 15% do total de ativos sob sua gestão (AuM total).

63. A defesa aduziu, ainda, que, no período entre 2004 e 2007, a Cartinvest: (i) teria representado ainda a maior receita individual gerada para a ARX, cerca de 25% do total; (ii) teria gerado aproximadamente 35% de toda a receita de performance da ARX no período, sendo a maior representatividade individual dentre as carteiras geridas pela ARX; (iii) teria apresentado taxa efetiva de gestão considerando performance (“ROA”) de aproximadamente 3,06% a.a., sendo este um dos maiores ROAs dentre os fundos geridos pela ARX no período, embora tivesse uma taxa de administração de 1% a.a.

IV.5. Motivação inverossímil (2): irrelevância dos supostos benefícios advindos da concentração de operações com ajustes negativos para o Fundo ARX Strike

64. A defesa criticou a tese da acusação de que a especificação das piores operações para o Fundo ARX Strike decorreria do fato de que a taxa de performance desse fundo seria inferior à dos demais fundos geridos pela ARX.

65. Apontou, nesse sentido, que, ao contrário do alegado pela a Acusação, a taxa de performance efetiva dos demais fundos geridos pela ARX seria menor do que os 20% mencionados, uma vez que grande parte das aplicações nesses fundos viria através de distribuidores, que recebem rebate. A defesa afirmou, portanto, que, descontado o rebate, a remuneração média de performance seria de, aproximadamente, 14,9% e não de 20%. A defesa alegou, ainda, que, no ano de 2007, 43% dos fundos estavam, em média, abaixo da linha d’água nos dias anteriores aos de negociação de Índice com ajustes negativos.

66. Diante desse quadro, a defesa pontuou que a caso a ARX estivesse atuado segundo a tese da Acusação, teria “transferido ganhos da carteira mais representativa da casa para fundos que, na maioria das vezes, não estavam gerando o pagamento de remuneração de performance”¹⁴.

¹⁴ Item 176 da defesa.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

67. A defesa apresentou, ainda, estudo (fls. 1.904-1.913) com o objetivo de analisar o impacto que uma alocação pro-rata patrimônio líquido entre os fundos que negociaram futuros de Índice em 2007 teria sobre a receita de taxa de performance para a ARX¹⁵. Com efeito, o resultado apresentado pela defesa indicou que o esquema aventado pela acusação teria incrementado a remuneração de performance da ARX em pouco mais de R\$14 mil, no ano de 2007. Diante desse resultado, a defesa sustentou não ser “razoável ou sequer crível que quem quer que seja – ainda mais tão reputada casa de gestão – implementasse tamanho esquema com o exclusivo objetivo de, ao final, incrementar suas receitas em valor tão insignificante, inferior a 0,03% da receita da ARX no ano de 2007”¹⁶.

IV.6. Uso de prova indiciária

68. A defesa argumentou que as provas trazidas pela Acusação seriam meramente indiciárias. Sobre isso, afirmaram que, no direito brasileiro, apesar de admitida em nosso ordenamento jurídico, a prova indiciária deveria ser utilizada “com extrema cautela”, pois ela poderia ser invalidada não só por contra indícios, como por qualquer outra prova contrária.

IV.7. Responsabilidade do BNY Mellon e seu diretor responsável

69. Com relação à acusação feita contra o BNY Mellon, a defesa alegou que as conclusões da Acusação seriam infundadas.

70. Segundo a defesa, a Acusação partiria do pressuposto de que o Administrador Fiduciário não teria “acompanhado, sequer minimamente, as atividades desenvolvidas pelo gestor”, o que caracterizaria suposta falha em seu dever de supervisionar a ARX e, também, uma falha no seu dever de diligência.

71. A Acusação teria, contudo, se baseado em uma leitura distorcida de uma declaração do Administrador Fiduciário de que não adotaria controles ou mecanismos de verificação em relação aos critérios de grupamento e rateio de ordens de negociação para os gestores de fundo de investimento sob sua administração. A defesa afirmou que não haveria, nessa passagem, confissão do Administrador Fiduciário de que não cumpria com suas funções. Na realidade, ela

¹⁵ O estudo simula quanto seria a receita de performance devida por todos os fundos (incluindo a Cartinvest) caso todas as operações realizadas da Conta Máster pelo Fundo ARX Strike tivessem sido alocadas *pro-rata* patrimônio líquido em relação todos os fundos (inclusive a Cartinvest). Feito o cálculo, comparou-se essa remuneração simulada com a receita real de performance gerada no ano 2007 para a ARX.

¹⁶ Item 183 da defesa.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

apenas afirmava ser impossível fazer a verificação da forma como pretendida pela Comissão de Inquérito.

72. Nesse sentido, a defesa argumentou que o administrador poderia verificar a existência da política e testar, por amostragem, a aderência a tal política. No entanto, o administrador não teria como exercer o controle sobre cada operação, inclusive por não ter acesso à conta máster mantida pelo gestor na corretora de sua escolha, visto que já receberia as informações das operações rateadas por fundos.

73. A defesa indicou, ainda, que os controles da ARX referentes à política de *fair allocation* foram objeto de auditoria da SIN entre os anos de 2009 e 2010, que concluiu que, de modo geral, os critérios de rateio adotados pela Gestora eram aplicados de modo consistente e sistemático. A Acusação estaria, portanto, exigindo do Administrador Fiduciário um tipo de detecção que nem a SIN teria sido capaz de fazer. Ressaltou, ainda, que a Acusação levou anos para concluir pela alegada inobservância da política de *fair allocation* pela ARX.

IV.8. Responsabilidade dos diretores responsáveis do Gestor e do Administrador Fiduciário

74. Com relação aos diretores responsáveis, a defesa pontuou que o dever de diligência os obrigaria a monitorar o desenvolvimento das atividades da instituição como um todo. Esse monitoramento, portanto, não os obrigaria a investigar, em detalhes, todas as atividades desempenhadas, sendo-lhes autorizado confiar em seus controles e no trabalho de profissionais qualificados. As informações provenientes de tais controles e profissionais devem ser analisadas de forma crítica, verificando se são suficientes e se há indicação de alguma irregularidade ou falha que possa causar danos ao mercado e aos clientes da instituição. Apresentou, em reforço ao seu argumento, trechos de diversas decisões da CVM, tais como o Processo Administrativo Sancionador nº 2006/4663, j. em 04.09.2007, e o Processo Administrativo Sancionador CVM nº 13/2005, j. em 25.06.2012.

75. No caso dos autos, destacou a defesa, a própria Acusação reconhecia que o critério adotado pela ARX era utilizado pelo menos desde 2002. Ressaltou, ademais, que os critérios foram exaustivamente discutidos com a SIN, que naquela ocasião concluiu pela sua suficiência e adequação às normas aplicáveis.

76. Assim, ainda que se ignorassem todos os argumentos que afastam por completo qualquer tipo de irregularidade no Fundo ARX Strike, e se acreditasse que a política de *fair allocation* não



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

foi observada, não haveria qualquer evidência, nos autos do presente processo, da suposta negligência dos diretores responsáveis na implantação de controles internos.

IV.9. Parecer jurídico

77. Em novembro de 2018, foi apresentado um parecer jurídico elaborado por Otavio Yazbek. Em reforço aos argumentos de defesa, o parecerista conclui pela ausência de um conjunto probatório minimamente robusto e convergente com o qual se possa afirmar, com a necessária segurança, que a conduta da ARX preenche os elementos caracterizadores do uso de prática não equitativa.

V. PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO

78. Em 14.03.2014, os Defendentes apresentaram proposta conjunta de termo de compromisso, por meio do qual se propuseram a pagar o valor de R\$675.000,00 (seiscentos e setenta e cinco mil reais), sendo **(i)** R\$300.000,00 (trezentos mil reais) a serem pagos pela ARX; **(ii)** R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a serem pagos por Carlos Ramos; **(iii)** R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a serem pagos por BNY Mellon; e **(iv)** R\$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) a serem pagos por José Carlos Lopes.

79. Ao apreciar a proposta apresentada, a PFE opinou pela sua rejeição. Em 17.11.2014, os Acusados apresentaram pedido de reconsideração, que foi novamente rejeitado pela PFE e, em seguida, pelo Comitê de Termo de Compromisso.

80. Em reunião de 30.08.2016, o Colegiado, acompanhando o entendimento do Comitê, deliberou rejeitar a proposta de termo de compromisso apresentada.

VI. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

81. Este processo foi originalmente distribuído para o então Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes, a quem substituí no Colegiado. Ao final do seu mandato – e antes de minha posse – o processo foi provisoriamente redistribuído, até que, no dia 14.07.2017, fui designado seu relator. É o relatório.

Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2019

Gustavo Machado Gonzalez



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Diretor Relator



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 05/2012

Reg. Col. nº 0342/2016

Acusados: ARX Capital Management Ltda.
Carlos Eduardo Teixeira Ramos
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
José Carlos Lopes Xavier de Oliveira

Assunto: Apurar eventuais irregularidades envolvendo negócios efetuados por fundos de investimentos geridos pela ARX Capital Management Ltda.

Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

VOTO

I. INTRODUÇÃO

1. Conforme narrado no relatório, este PAS envolve cinco imputações distintas.
2. A ARX¹ é, em primeiro lugar, acusada de ter infringido o artigo 14, II, da Instrução CVM nº 306/1999 e o artigo 60, parágrafo único, c/c artigo 65-A, I, ambos da Instrução CVM nº 409/2004 por não ter implementado sistema que estabelecesse critério equitativo para rateio das ordens de compra e venda dadas de forma agrupada para os diversos fundos geridos pela instituição entre 2003 e 2006. Foi, ainda, acusada de realizar prática não equitativa no mercado de valores mobiliários (definida no item II, letra “d”, da Instrução CVM nº 08/1979 e vedada pelo item I da mencionada Instrução) no ano de 2007.
3. Carlos Ramos, diretor responsável pela atividade de administração de carteiras de valores mobiliários da ARX no período coberto pelo processo, foi acusado de não ter empregado os devidos cuidado e diligência em promover a implantação de sistemas de controles internos que assegurassem o atendimento da regulação em vigor, especialmente no que se refere aos critérios

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

de rateio de ordens (violação ao artigo 14, II, da Instrução CVM nº 306/1999 e ao artigo 60, parágrafo único, c/c artigo 65-A, I, ambos da Instrução CVM nº 409/2004).

4. Já BNY Mellon foi acusada de infringir o artigo 65, XV, c/c artigo 65-A, I, ambos da Instrução CVM nº 409/2004 por não ter observado nem o dever de fiscalizar a Gestora, nem o seu dever de diligência.

5. Por fim, José Carlos Lopes foi acusado de não ter empregado os devidos cuidado e diligência para promover a implantação de sistema de controles internos com vistas a garantir o atendimento à legislação em vigor especialmente no que se refere aos critérios de rateio de ordens. Assim como no caso do Administrador Fiduciário, a acusação é de infração ao artigo 65, XV, c/c artigo 65-A, I, ambos da Instrução CVM nº 409/2004

6. Preliminarmente, analisarei a alegação sobre suposta prescrição de pretensão punitiva, conforme previsto no artigo 1º, *caput*, da Lei nº 9.873/1999. Em relação ao mérito, tratarei, primeiramente, das acusações relacionadas à inexistência de um sistema de rateio de ordens equitativo e preestabelecido, para, em seguida, examinar a acusação de prática não equitativa.

II. PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO

7. Preliminarmente, os Acusados alegam a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva da CVM no que diz respeito às operações compreendidas entre 2003 e 2006, argumentando que as investigações a respeito destes negócios somente se iniciaram quando da instauração do inquérito administrativo em 2012, ou seja, depois de transcorridos mais de cinco anos da data da última operação potencialmente irregular do ano de 2006.

8. Para analisar esse argumento, julgo pertinente tecer breves considerações sobre a possibilidade de a acusação, na fase investigativa, retroceder a apuração a um período anterior àquele originalmente analisado e, em caso afirmativo, como deve se dar a contagem do prazo prescricional.

9. Com relação ao primeiro ponto, o Colegiado já decidiu que as portarias do Superintendente Geral que determinam a instauração de inquérito administrativo não delimitam de modo exaustivo o escopo dos trabalhos de investigação e, consequentemente, o que pode ser objeto de uma eventual acusação. Sobre essa questão, assim se manifestou a então Diretora Relatora Maria Helena Santana no Processo Administrativo Sancionador no PAS CVM nº 02/03:

“A Portaria tem por objetivo estabelecer linhas gerais para a atuação da Comissão de Inquérito, motivada por indícios de ocorrência de ilícitos em determinado episódio (...). Não se trata, portanto, de



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

despir de poderes a Comissão, restringindo sua atuação única e exclusivamente às suspeitas inicialmente levantadas, fechando-lhe os olhos a outros ilícitos que possam eventualmente ter ocorrido. Há de se convir que, num procedimento investigatório, não é possível prever o que irá surgir e, caso surjam evidências de outros ilícitos, é dever da Comissão apurá-los”².

10. No entanto, ainda que a acusação possa abranger fatos não previstos na portaria de instauração de inquérito administrativo, isso não significa que todo e qualquer fato novo que a área técnica venha a apurar estará, automaticamente, abarcado pela investigação original. O prazo para prescrição da pretensão punitiva somente é interrompido nas hipóteses do artigo 2º da Lei nº 9.873/1999, dentre as quais ressalto o ato inequívoco que importe em apuração dos fatos. A toda evidência, a apuração de certos fatos não interrompe a prescrição da pretensão punitiva referente a outro conjunto de fatos³.

11. A análise da GMA-2 que deu origem a este processo começou ainda no ano de 2007. Ao contrário do que alega a defesa, as apurações iniciais da referida gerência não se limitaram ao ano de 2007. De fato, alguns dos primeiros ofícios enviados pela GMA-2 – de nº 199/07 (fls. 146), 200/07 (fls. 162) e 201/07 (fls. 143), todos de 22.11.2007 – solicitaram à ARX, ao BNY Mellon e ao Investvale, respectivamente, informações sobre as operações realizadas pelo clube no período de 31.12.2005 a 31.10.2007. Cabe ressaltar que o ofício enviado à Gestora solicitava, inclusive, “uma descrição detalhada de como são efetuadas as especificações das operações realizadas pelo comitente” (i.e. pelo Investvale).

12. A defesa enfatiza que o Relatório GMA-2 identificou indícios de irregularidade no ano de 2007 e que a portaria de instauração do inquérito administrativo, de 08.06.2012, tinha por objeto apurar “eventuais irregularidades envolvendo negócios efetuados por fundos de investimentos geridos pela ARX Capital Management Ltda. no mercado futuro de Ibovespa na BM&F no período de janeiro a dezembro de 2007”. Mais ainda, aponta que a própria Acusação reconhece que “com o aprofundamento das investigações (...) apurou-se um padrão de conduta recorrente por parte da gestora capaz de produzir prejuízos ao ARX Strike ao menos desde o ano de 2003.

² PAS CVM nº 02/03, Diretora Relatora Maria Helena Santana, julgado em 24.01.2007.

³ Veja-se, nesse sentido, o voto do Diretor Relator Marcos Pinto no julgamento do PAS CVM nº 23/05, j. em 02.10.2007. Assim como naquele caso, não me parece correto aplicar ao caso as regras próprias de infrações de caráter permanente ou continuado.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Desta forma, o período de análise das operações realizadas em nome do fundo, *inicialmente concentrado no ano de 2007*, foi ampliado, retrocedendo ao ano de 2003”⁴.

13. Como bem aponta a defesa, o fato de o relatório GMA-2 ter, em uma rápida passagem, mencionado, “como ilustração”, os anos de 2004 a 2006 naturalmente não faz com que o referido documento se caracterize como ato inequívoco de apuração relativo a esse período – o documento, inclusive, enfatiza que o “escopo desta análise será restrito ao ano de 2007”. Contudo, do mesmo modo, também entendo que o fato de o referido relatório e de a portaria de instauração do inquérito terem feito referência expressa apenas ao ano de 2007 não faz com que os atos de apuração relativos ao período anterior (que cobre desde 31.12.2005) deixem de ser causas interruptivas da prescrição.

14. Assim, a meu ver, a defesa tem parcial razão no que se refere à prescrição. Está prescrita a pretensão punitiva da CVM no que se refere aos fatos ocorridos entre os anos de 2003, 2004 e 2005 (excetuando o dia 31.12.2005), uma vez que esse período somente passou a integrar o objeto do processo a partir da instauração do inquérito administrativo em 18.06.2012. A prescrição, contudo, não alcança os fatos ocorridos entre 31.12.2005 e 31.12.2006, uma vez que a GMA-2 iniciou a análise desse período ainda em 2007.

III. MÉRITO

III.1. Inexistência de um sistema de rateio de ordens equitativo e preestabelecido

ARX

15. Começo o exame do mérito analisando se a ARX possuía sistema que lhe permitia ratear, através de critérios preestabelecidos e equitativos, as ordens de compra e venda dadas de forma agrupada para os diversos fundos geridos pela instituição. A existência dos referidos sistemas, como se sabe, é condição necessária para que a pessoa jurídica que administra diversos fundos possa emitir ordens de forma grupada⁵.

16. A ARX reconhece que, durante o período em análise, concentrava as posições dos fundos que geria e que operaram índices futuros em uma conta máster. Segundo a Gestora, a prática buscava maior eficiência operacional, ao reduzir os custos de corretagem – o intermediário, no

⁴ Item 171 do Relatório da Comissão de Inquérito.

⁵ V. artigo 60, parágrafo único, da Instrução CVM nº 409/2004. A exigência hoje consta do artigo 82, parágrafo único, da Instrução CVM nº 555/2014, editada em substituição à Instrução CVM nº 409/2004.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

caso, era um *discount broker* – e centralizar a liquidação, facilitando a centralização das margens.

17. A Gestora argumenta que as ordens dadas para determinada família de fundos eram sempre proporcionalmente rateadas. Já as ordens dadas para fundos que não pertenciam a nenhuma família – como é o caso do Fundo ARX Strike – seriam sempre emitidas e registradas em nome desse fundo e integralmente alocadas a ele. Ou seja, segundo a ARX, jamais haveria rateio de ordens entre fundos de diferentes famílias.

18. A Acusação não analisa se as ordens dadas para fundos de uma determinada família foram rateadas de forma proporcional. Seu foco, desde o início, foi apurar se certas operações realizadas por meio da conta máster foram especificadas para o Fundo ARX Strike ao final do pregão, quando já se sabia que o ajuste do dia era negativo, a fim de evitar que tais resultados fossem alocados para outras carteiras administradas pela Gestora.

19. A tese da Acusação é baseada em uma aparente dissonância entre o que a Gestora dizia fazer e aquilo que se verificava na prática. Afinal de contas, em determinados pregões, a conta máster registrou operações tanto para o Fundo ARX Strike como para fundos de outras famílias. Em outros, a conta máster foi utilizada embora o referido fundo tenha sido o único a operar com índices futuros. Se as ordens do Fundo ARX Strike eram de fato emitidas de forma individualizada, como alega a Gestora, como explicar esses fatos?

20. Nos memoriais, a defesa trouxe esclarecimentos adicionais sobre esse ponto. Explicou, então, que qualquer ordem transmitida através da conta máster era anteriormente registrada em um sistema interno da Gestora, baseado em planilhas de Excel disponíveis de forma transparente em um diretório público para todos os gestores das famílias de fundos, o *middle office* e o *back office* e os diretores de risco e de *compliance*. Tais planilhas, no entanto, não estariam mais disponíveis, tendo em vista o tempo transcorrido – mais de 10 anos. Desse modo, para a alocação das ordens ao Fundo ARX Strike a partir da conta máster, bastava que se olhasse para as planilhas de *Excel* públicas nas quais as ordens em seu nome haviam sido previamente registradas pelo gestor responsável.

21. Em linha com o que decidiu o Colegiado no julgamento do PAS CVM nº RJ2010/13301 (j. em 23.10.2012, Diretora Relatora Luciana Dias), entendo que a exigência prevista no artigo 60, parágrafo único, da Instrução CVM nº 409/2004 pode ser satisfeita tanto com regras escritas como por registros eletrônicos. Ressalto, ainda, que não podemos julgar fatos passados com os olhos de hoje. O exame do comportamento dos agentes do mercado em um determinado período



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

deve, necessariamente, considerar as práticas do mercado à época, incluindo – e esse ponto é especialmente relevante em obrigações cujo cumprimento se dá por meio da adoção de sistemas, controles e procedimentos – as tecnologias então disponíveis e utilizadas.

22. Assim, em teoria, o argumento da defesa parece apto a afastar a acusação. A rigor, se cada ordem dada através da conta máster era previamente especificada, somente as ordens dadas em nome de uma família de fundos consistiam verdadeiramente em ordens grupadas, passíveis de posterior rateamento (entre os fundos daquela família). Em outras palavras, não seria cabível falar em rateio de uma ordem dada para um fundo específico, ainda que transmitida por meio da conta máster. Naturalmente, não se pode ir tão longe a ponto de defender que a alegada prática da Gestora estaria fora do alcance do artigo supostamente infringido, com base no argumento de que não haveria um verdadeiro grupamento de ordens – sob pena de se negar a finalidade ao citado dispositivo⁶.

23. Esse ponto, aliás, talvez explique a razão pela qual acusação e defesa se valem dos mesmos trechos das declarações colhidas ao longo do processo com o objetivo de comprovar teses diametralmente opostas. Com efeito, a suposta contradição apontada pela Acusação pode ter decorrido do fato de que as pessoas da Gestora ouvidas na fase de apuração entendiam que o universo de ordens passíveis de rateio era substancialmente menor do que aquele que estava sendo considerado pela área técnica. Pode, também, ser a razão pela qual as operações realizadas para o Fundo ARX Strike por meio da conta máster não podem ser explicadas pela política de *fair allocation*. Mais ainda, se a especificação era feita em um sistema interno da Gestora, é normal que os funcionários da corretora não o tenham mencionado.

24. No entanto, a Gestora não logrou demonstrar que o alegado sistema de registro de ordens realmente existia. A explicação fornecida, ainda que me sensibilize, não é apta a, sozinha, afastar a acusação de infração ao artigo 60, parágrafo único, da Instrução CVM nº 409/2004. Referido dispositivo é claro ao exigir que o sistema não só seja previamente formalizado como, também, fique à disposição da CVM pelo prazo de cinco anos. Ou seja, a não apresentação do sistema em que critérios equitativos para rateio foram preestabelecidos configura infração ao artigo 60,

⁶ A CVM, vale dizer, foi progressivamente restringindo o uso da conta máster, impondo limites de tempo para a especificação do investidor a partir da concretização do negócio, não mais permitindo, como regra geral, sua realização ao fim do dia. Atualmente, a regra aplicável aos intermediários determina a especificação do comitente final dos negócios comandados por meio de sua mesa de operações no prazo máximo de 30 (trinta) minutos após o registro do negócio nos termos do artigo 22, § 2º da Instrução CVM nº 505/2011.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

parágrafo único, da Instrução CVM nº 409/2004 mesmo na hipótese de a gestora ser capaz de demonstrar que as ordens transmitidas de forma agrupada vinham sendo efetivamente rateadas.

25. Ademais, embora cause espécie a paralisação da análise entre 2008 e 2012, o tempo transcorrido não exime a ARX de responsabilidade: afinal de contas, ainda em 2007, a Gestora recebeu questionamentos da CVM acerca das operações que realizava para os fundos e carteiras geridos, com especial foco no Fundo ARX Strike. Entendo, portanto, que a ARX deve ser responsabilizada por infração ao referido dispositivo e ao artigo 14, II, da Instrução CVM nº 306/1999. Na dosimetria da pena, considerarei os bons antecedentes da acusada.

26. De outro lado, entendo que a Gestora não pode ser condenada por infração ao artigo 65-A, I, da Instrução CVM nº 409/2004, uma vez que o referido comando foi incluído pela Instrução CVM nº 450/2007, de 30.03.2007, e o período coberto pela primeira imputação vai até o final de 2006.

Responsabilidade do Diretor Responsável da Gestora

27. Passo agora ao exame da responsabilidade de Carlos Ramos, diretor responsável pela atividade de administração de carteiras de valores mobiliários da ARX no período coberto pelo processo. Segundo a Acusação, Carlos não teria empregado os devidos cuidado e diligência em promover a implantação de sistemas de controles internos que assegurassem o atendimento da regulação em vigor, especialmente no que se refere aos critérios de rateio de ordens.

28. O fato de a regulação da CVM prever a figura do diretor responsável não significa que ele deva ser automaticamente apenado em casos em que se concluir pela responsabilidade da pessoa jurídica. No direito administrativo sancionador, a responsabilidade é sempre subjetiva e depende da demonstração de dolo ou culpa.

29. O diretor responsável se desincumbe do seu dever de supervisionar as atividades da entidade ao fazer com que essa adote sistemas, procedimentos e controle eficazes. As informações geradas por tais sistemas devem, é claro, ser analisadas de forma crítica. A toda evidência, eventuais indícios de irregularidade devem ser investigados, mas não se pode perder de vista a dimensão sistêmica das obrigações de controle. Falhas isoladas, portanto, a princípio não acarretam responsabilidade ao diretor responsável.

30. Como ressaltei acima, entendo que a Acusação reuniu elementos que demonstram que a Gestora não adotou procedimentos que formalizassem critérios para o uso da conta máster para fundos que não eram da mesma família. Tampouco restaram evidenciados eventuais esforços do



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

diretor responsável para implementar a formalização de tais critérios. Noto, nesse sentido, que a política de *fair allocation* não explica como as ordens de um fundo que não participava de uma família poderiam ser realizadas por meio da conta máster: ao contrário, prevê que “todas as ordens para esses fundos são realizadas sempre individualmente”.

31. A defesa alega que as ordens eram previamente registradas em um sistema interno, mas, como dito acima, não trouxe evidência de que o referido sistema de fato existia.

32. Entendo que o problema não pode ser considerado uma falha isolada, por pelo menos duas razões. A uma, porque envolveu uma decisão consciente da ARX, que durante o período analisado deliberadamente optou por concentrar as posições dos fundos que geria e que operaram índices futuros em uma única conta máster. Ainda que as justificativas apresentadas possam ser consideradas válidas à luz das práticas de mercado à época, a Gestora necessariamente deveria ter adotado controles formais estabelecendo como a conta máster seria utilizada nesses casos. A duas, porque os fundos que não participavam de nenhuma família tinham relevância para a Gestora, sendo que a carteira do Investvale representava, à época, parcela expressiva dos recursos geridos e das receitas auferidas pela ARX.

33. Diante desses fatos, entendo que Carlos Ramos violou o artigo 14, II, da Instrução CVM nº 306/1999 e o artigo 60, parágrafo único, c/c artigo 65-A, I, ambos da Instrução CVM nº 409/2004. Especificamente com relação a esse último artigo, a condenação abarca somente o período a partir da entrada em vigor da Instrução CVM nº 450/2007. Na dosimetria da pena, considerarei os bons antecedentes do acusado.

Responsabilidade do Administrador Fiduciário

34. BNY Mellon foi acusado por uma suposta falha em seu dever de supervisionar a ARX, conforme preceitua o artigo 65, XV, da Instrução CVM nº 409/2009, o que também denotaria uma falha no seu dever de diligência, previsto no artigo 65-A, inciso I, da mesma Instrução.

35. O exame da responsabilidade dos administradores fiduciários e dos gestores de carteira não pode ignorar os diferentes papéis desempenhados por cada um desses agentes. Em casos recentes, por exemplo, os administradores foram absolvidos quando os fatos que motivaram a



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

acusação se referiam especificamente às decisões de investimento, que são de competência ordinária do gestor⁷.

36. Historicamente, a regulamentação da CVM assume um protagonismo dos administradores fiduciários na condução das atividades dos fundos de investimentos. Com efeito, a administração de carteiras de valores mobiliários é, ainda hoje, definida de modo genérico abrangente como “o exercício profissional de atividades relacionadas, direta ou indiretamente, ao funcionamento, à manutenção e à gestão de uma carteira de valores mobiliários”⁸. A explicação, creio eu, reside no fato de que os poucos dispositivos legais que tratam da indústria de fundos não foram alterados à medida em que o mercado se tornou mais complexo e as atividades que originalmente eram concentradas em uma única entidade foram progressivamente sendo segregadas em prestadores de serviço autônomos e especializados.

37. Na regulamentação vigente, portanto, cabe ao administrador fiduciário exercer diretamente todas as atividades necessárias para a manutenção do fundo de investimento ou, o que é mais comum, parcialmente delegá-las a terceiros. Na prática, os administradores usualmente terceirizam uma série de serviços fiduciários – incluindo não só a gestão da carteira, como, por exemplo, a distribuição de cotas e as atividades de tesouraria, escrituração de cotas e custódia de ativos financeiros – mantendo, contudo, responsabilidade por supervisionar os serviços delegados a terceiros.

38. Esse dever de monitoramento do administrador fiduciário precisa ser interpretado de forma cuidadosa. Como disse recentemente⁹, as diversas representações do dever de diligência – em especial, aquela associada ao dever de fiscalizar – não podem ser lidas de modo excessivamente abrangente, sob pena de se criarem expectativas irreais de comportamento e parâmetros despropositadamente rigorosos de revisão que, ao final, na indústria de fundos, tendem a criar redundâncias descabidas e custos desnecessários¹⁰.

⁷ Processo Administrativo Sancionador CVM SEI nº 00783.001.807/2015-94 (RJ2015/12087), Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 24.07.2018.

⁸ V. artigo 1º da Instrução CVM nº 558/2015.

⁹ Processo Administrativo Sancionador CVM SEI nº 19957.006758/2017-37 (RJ2013/8880), Dir. Rel. Henrique Machado, j. em 11.06.2019.

¹⁰ Cabe aqui um paralelo com o dever de diligência dos administradores de companhias e, em especial, referência ao que disse Luiz Antonio de Sampaio Campos sobre o assunto: “Os conceitos adotados pela LSA, a par de representarem comportamentos positivos e negativos, em sua maioria revestem-se de formas amplas, largas, referindo-se a padrões de conduta ou ‘standards’, o que confere ao intérprete e ao aplicador da lei uma certa



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

39. Feitas essas observações, volto ao caso em tela, em que se discute a responsabilidade do Administrador Fiduciário pela supervisão da Gestora, especialmente no que se refere aos sistemas mantidos por essa última para rateio de ordens.

40. Não há dúvida de que a responsabilidade por implantar um sistema que possibilite o rateio equitativo de ordens transmitidas de forma agrupada é do gestor. Afinal de contas, compete ao gestor emitir as ordens de compra e venda de ativos financeiros para os fundos cuja carteira administra; consequentemente, cabe também a ele a decisão sobre o eventual agrupamento de ordens para posterior distribuição entre os fundos de investimento geridos. Esse fato não significa que o administrador fiduciário não tenha responsabilidade por monitorar a atuação do gestor no que se refere ao rateio de ordens, mas determina a forma como esse monitoramento pode e deve ser feito.

41. O administrador fiduciário pode e deve verificar se o gestor que se vale da faculdade de transmitir ordens de forma agrupada possui políticas que atendam aos requisitos estabelecidos na regulamentação. Deve, ainda, periodicamente confirmar se as ordens transmitidas de forma agrupada estão sendo rateadas de modo aderente à política. Contudo, como bem aponta a defesa, não pode o administrador, que não tem acesso à conta máster mantida pelo gestor na corretora de sua escolha e já recebe as informações das operações rateadas por fundos, fazer um controle como aquele exigido pela Acusação.

42. Noto, por fim, que a SIN testou a política de *fair allocation* utilizada pelas gestoras do grupo Mellon e concluiu que, salvo por questões pontuais, os critérios de rateio formalmente previstos eram aplicados de maneira consistente. A própria SIN, em sua análise, não identificou qualquer problema em razão da utilização da conta máster para fundos que não integravam nenhuma família.

43. Diante do exposto, não vejo como concluir que o Administrador Fiduciário falhou em seu dever de supervisionar a ARX ou atuou sem a devida diligência. Assim, voto pela absolvição do BNY Mellon e de seu diretor responsável.

liberdade ou largueza de interpretação. Essa liberdade, típica das cláusulas gerais e dos conceitos jurídicos indeterminados, deve, porém, ser usada de forma inteligente e cuidadosa, a manter o sistema íntegro, para não desencorajar e afastar pessoas honestas e competentes dos cargos de administração, e também de modo a não criar um sistema que as entorpeça a ação com uma burocracia prejudicial à vida da companhia, afastando-as do risco inerente ao negócio” CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio. “Conselho de Administração e Diretoria”. In: LAMY FILHO, Alfredo e BULHÕES PEDREIRA, José Luiz (Org.). *Direito das Companhias*. 1ª Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2009, Vol. 1, p. 1087.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

III.2. Prática Não Equitativa

44. A ARX é, ainda, acusada de ter intencionalmente distribuído de forma irregular as ordens de compra e venda dadas por meio da conta máster, com o propósito de direcionar os prejuízos ao Fundo ARX Strike e beneficiar outros fundos geridos pela Gestora no ano de 2007. Por tal motivo, foi acusada de realizar prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, definida no item II, letra “d”, da Instrução CVM nº 08/1979 e vedada pelo item I da mencionada Instrução.

45. Em resumo, a referida imputação é fundamentada com base nos seguintes elementos: **(a)** a ausência do critério de rateio de ordens, **(b)** o fato de que as operações eram intermediadas por uma única corretora, e **(c)** em dados estatísticos. Aponta, ainda, uma possível motivação para a prática do ilícito: o fato de que a taxa de performance do Fundo ARX Strike era inferior à dos outros fundos geridos pela ARX.

46. O fato de a Gestora não ter sido capaz de demonstrar a existência de sistemas de rateio preestabelecidos não é suficiente para comprovar a prática não equitativa, cuja caracterização, como, aliás, a dos demais tipos da Instrução CVM nº 08/1979, requer a demonstração de dolo ou, ao menos, de culpa grave, equiparada ao dolo eventual¹¹.

47. A própria Acusação, aliás, parece concordar com esse fato. Tanto assim que, embora tenha concluído que o referido sistema não existia ao menos desde 2003, optou por separar a conduta da Gestora em dois períodos, acusando-a da conduta mais grave – a prática não equitativa – apenas para os atos praticados no ano de 2007. É importante ressaltar que, durante todo o período, as posições dos fundos geridos pela ARX e que operaram índices futuros foram concentradas na conta máster mantida na mesma corretora.

48. Por qual razão então a Acusação entendeu que a conduta da Gestora foi mais grave no ano de 2007? Basicamente, o que diferencia esse último ano dos demais, segundo a análise da Acusação, é o resultado dos experimentos estatísticos por ela realizados, que, somados aos elementos acima mencionados, formariam um “conjunto idôneo e convergente de indícios que apontam para a intencional distribuição irregular das ordens de compra e venda com o propósito

¹¹ Nas palavras do ex-presidente da CVM Marcelo Trindade, “no que se refere à Instrução 08/79, parece-me evidente que não se pode falar em simples negligência, para condenar-se algum agente com base naquela norma. Ou se está diante de dolo, ou ao menos, em meu pessoal entendimento, de culpa grave, equiparada ao dolo eventual [...]” (Voto proferido no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM nº 16/02, acompanhado pelos demais membros do Colegiado, julgado em 10.10.06).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

de direcionar os prejuízos ao Fundo ARX Strike e beneficiar outros fundos geridos pela ARX Capital.¹²”

49. Com o intuito de demonstrar o dolo da conduta da ARX – insisto: elemento essencial para a caracterização da prática não equitativa –, a Acusação aponta, ainda, a suposta motivação do Gestor em aumentar a sua remuneração, destinando as operações mais lucrativas para os fundos que lhe pagavam maiores taxas de performance.

50. Começo pela **prova estatística**, principal motivo para a segregação da acusação em dois períodos distintos.

51. Os dados estatísticos são elementos que podem contribuir para o convencimento do julgador. No entanto, deve-se ter muito cuidado no manejo de dados estatísticos e consciência do que pode, efetivamente, ser demonstrado pela estatística. Sobre o assunto, vale citar a lição de Michele Taruffo:

“No âmbito das provas científicas, um tema peculiar é o uso de estatísticas como elementos de prova. Em verdade, as provas estatísticas têm adquirido cada vez mais importância nas últimas décadas (...). Todavia, surgem problemas relevantes relativamente ao uso apropriado das estatísticas como meio de prova. Alguns desses problemas relacionam-se ao fato de que a utilização apropriada das estatísticas é uma tarefa muito complexa e delicada, na qual erros e mal-entendidos são muito frequentes. Outra questão é se as chamadas «estatísticas puras» podem ser usadas para provar a existência de um fato específico. Apesar de alguns argumentos aduzidos a favor do uso probatório das estatísticas puras, a opinião amplamente dominante é no sentido de que estatísticas não podem oferecer um suporte probatório válido a um enunciado sobre um fato específico, posto que somente podem determinar a frequência relativa de classes de eventos. É claro que isso não significa que estatísticas não possam ou não devam ser usadas como prova: significa que, em geral, essas não são suficientes per se para que se estabeleça a probabilidade da ocorrência de um fato específico. Por outro lado, se o «fato» a ser provado é somente a frequência relativa de duas classes de eventos, estatísticas podem ser a prova adequada de tal fato. (...) Portanto, pode-se afirmar que não há bons argumentos contra o uso de provas estatísticas quando essas são diretamente relevantes aos fatos em litígio; porém deve-se ressaltar que fazer o uso correto de tais provas pode ser extremamente difícil e arriscado. Estabelecer a relevância dos

¹² O conjunto dos elementos apontados pela Acusação como caracterizadores da prática não equitativa e 2007 encontra-se transcrito no item 28 do relatório.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

dados estatísticos em um caso particular e determinar o valor probatório de tais dados para se provar um fato específico requer cautela e um treinamento especial no uso do cálculo próprio.”¹³

52. No contexto da CVM, as provas estatísticas são de especial relevância, por exemplo, para casos em que se discute o eventual descumprimento de obrigações de controle impostas aos participantes do mercado, que devem ser analisadas sob uma perspectiva sistêmica¹⁴. Já em casos que envolvem tipos dolosos, as provas estatísticas podem ser consideradas indícios válidos, mas sozinhas não são suficientes para sustentar uma condenação.

53. No caso em tela, todavia, me parece que a Acusação se escorou na suposta ausência de plausibilidade dos dados estatísticos obtidos para então buscar, nas negociações analisadas, elementos que pudessem demonstrar artificialidade nas alocações efetuadas – fazendo um caminho inverso daquele usualmente feito em casos similares.

54. A despeito da relevância dada pela Acusação aos dados estatísticos por ela trazidos, a meu ver, eles não são indícios aptos a robustecer a sua tese e autorizar a condenação, pois são contraditados pelos argumentos do Parecer Estatístico apresentado pela defesa. Assim, o que se discute no caso em tela não é a suficiência da prova estatística, mas a correção das análises estatísticas em que a Acusação se escora.

55. No meu entender, a defesa, com o Parecer Estatístico, logrou trazer uma série de elementos que colocam em xeque as análises realizadas pela Acusação (vide item 51 do relatório). Não pretendo aqui discutir cada uma das análises estatísticas, de modo individualizado ou minudente. Reportando-me, em benefício da síntese, aos resumos dos experimentos estatísticos trazidos pela Acusação e pela defesa, julgo que o trabalho realizado pelos pareceristas foi mais minucioso, tendo (i) considerado, por exemplo, um universo maior de operações, englobando todos 37 dias em que o Fundo ARX Strike negociou futuros de Índice Bovespa no ano de 2007 e (ii) apontado problemas em algumas das premissas utilizadas pela acusação (por exemplo, a de que as operações realizadas no mesmo dia são eventos independentes entre si).

56. Segundo o Parecer Estatístico, realizados os ajustes devidos, a probabilidade de o Fundo ARX Strike ter tido os resultados que teve seria de 13,7% – aproximadamente a mesma

¹³ TARUFFO, Michele. *A prova*. São Paulo: Marcial Pons, 2014, pp.98-99.

¹⁴ Sobre o assunto, reporto-me ao voto condutor que proferi em 13.08.2019 no julgamento do PAS CVM SEI nº 19957.002587/2017-77, de relatoria do Diretor Henrique Machado.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

probabilidade de se obter determinado número em um dado de 6 faces e infinitamente menor do que a probabilidade de 1 em 47 octilhões obtida pela Acusação.

57. Entendo não ser necessário, para fins desse julgamento, arbitrar qual a probabilidade correta. Parece-me, no entanto, forçoso reconhecer que a probabilidade real é muito menor do que aquela apontada pela Acusação. Ora, a Acusação havia concluído pela “recorrência, em anos anteriores a 2007, do padrão de concentração dos maiores prejuízos em ajustes do dia para o ARX Strike”¹⁵. Para ambos os períodos, foram realizadas análises estatísticas¹⁶. A razão pela qual dividiu a atuação da Gestora em dois períodos, formulando uma acusação de maior gravidade, baseada na Instrução CVM nº 08/1979, para o ano de 2007, foi justamente o fato de as análises estatísticas para esse último ano terem indicado probabilidades extremamente remotas. Assim, a se concluir que as probabilidades são bem diferentes daquelas trazidas pela Acusação, entendo que, pela própria lógica acusatória, fica prejudicada a caracterização da prática não equitativa.

58. De outro lado, o Parecer Estatístico indica ter identificado forte relação estatística entre a decisão do referido fundo de operar e a volatilidade do mercado,¹⁷ fato que não foi identificado para os demais fundos geridos pela ARX¹⁸. Esse fato pode ser considerado um contraindício, pois parece corroborar o argumento da defesa de que o Fundo ARX Strike operava uma estratégia contra cíclica.

59. Passo, agora, ao exame da suposta **motivação** da ARX para a realização das operações – que poderia servir como um indício do dolo da acusada, elemento essencial para a caracterização da prática não equitativa. Também nesse ponto entendo que a defesa apresentou sólidos argumentos indicando que a suposta motivação da ARX de obter, por meio da suposta prática não equitativa, maiores taxas de performance é bastante inverossímil. Isto porque a Acusação se baseou, tão somente, na comparação das taxas de performance previstas nos regulamentos. A defesa contra-argumentou com um exame mais refinado, que considera a taxa de performance

¹⁵ Item 95 do Relatório de Acusação.

¹⁶ Itens 58 a 80 do Relatório de Acusação para o período de 2007; itens 81-95 do Relatório de Acusação para o período de 2003 a 2006.

¹⁷ A propósito, constava do próprio regulamento do fundo que seu investimento “envolve um alto grau de risco adotaria “a estratégia de investir em títulos e valores mobiliários de alta volatilidade, que potencializam tanto o lucro como a perda, podendo gerar, inclusive, perdas temporais de patrimônio” (fls. 293).]

¹⁸ V. item II.4 do Parecer Estatístico.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

efetiva (i.e., ajustada para descontar o efeito de rebates) e que muitos dos fundos supostamente beneficiados estavam, quando da realização das operações, abaixo da linha d'água.

60. Com esses ajustes, verifica-se que o estudo, apresentado pela defesa, acerca do impacto de uma alocação *pro-rata* patrimônio líquido entre os fundos que negociaram futuros de índice em 2007 demonstrou que o suposto benefício da Gestora foi ínfimo, de menos de R\$15 mil (equivalente a 0,03% da receita auferida pela ARX no exercício em questão). Especialmente quando se considera que o Investvale era, então, um cliente extremamente relevante para a ARX, inclusive no tocante à receita, não me parece factível que as coisas tenham de fato transcorrido do modo descrito na Acusação. Assim, embora o argumento da Acusação seja, em tese, possível, deve ser afastado no caso concreto.

61. Entendo também que a rentabilidade do Cartinvest no período coberto por este PAS é outro contraindício. Sobre esse ponto, tem razão a defesa quando diz que o Fundo ARX Strike deve ser analisado em conjunto com a carteira do Investvale, e, portanto, a estratégia adotada pela Gestora deve ser interpretada considerando tanto a parcela à vista detida na carteira do Investvale quanto a parcela detida por meio do fundo – uma vez que este era um dos veículos utilizados pela estratégia “Cartinvest”. Mais especificamente, como já mencionado no relatório, o Fundo ARX Strike servia como instrumento para **(i)** gestão de liquidez para carteira, com o intuito de manter o caixa da Cartinvest investido e disponível para o atendimento de pedidos de resgates; e **(ii)** gestão da exposição líquida em renda variável da carteira da Cartinvest como um todo.

62. Naturalmente, o fato de o investidor supostamente prejudicado pela operação de seguro ter obtido lucro no período em que a infração teria sido praticada, inclusive nos negócios feitos em seu nome no contexto das operações do seguro, não é por si só determinante para afastar uma acusação de prática não equitativa. Nesse caso, contudo, os fatos parecem contradizer a tese acusatória. Tenho dificuldade para concluir, com base nas provas dos autos, que Fundo ARX Strike foi sistematicamente prejudicado em operações com índices para beneficiar outros fundos geridos pela ARX cujos regulamentos previam taxas maiores de gestão, quando constato **(i)** que a taxa efetiva de gestão do Cartinvest entre 2004 e 2007, considerando performance (“ROA”), foi de aproximadamente 3,06% a.a. - um dos maiores ROAs dentre os fundos geridos pela ARX no período; e **(ii)** que a rentabilidade do Cartinvest sistematicamente superou a dos Fundos Beneficiados – sendo que, especificamente no ano de 2007, no qual a prática não equitativa teria se consumado, o Cartinvest teve o melhor desempenho dentre as carteiras administradas pela ARX (38,7%).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

63. Assim, os únicos indícios que sobrevivem ao confronto com a defesa são **(i)** a utilização da conta máster e **(ii)** a incapacidade da Gestora de demonstrar a existência de sistemas de rateio preestabelecidos. Esses elementos, sozinhos, não bastam para concluir pela prática não equitativa. Nesse sentido, a defesa e o parecer jurídico posteriormente acostado apontam que o caso dos autos se diferencia dos típicos casos de operação de seguro analisados pelo Colegiado. Embora eu discorde da defesa e entenda que o referido ilícito pode, em teoria, ser caracterizado mesmo quando não se demonstra a existência de *day-trades*¹⁹, julgo que as provas dos autos são muito menos robustas do que aquelas constantes dos casos que resultaram em condenações²⁰.

64. Em resumo, entendo que não existe uma prova conclusiva de prática não equitativa. Tampouco há prova indiciária, que, como reiteradamente decidido por esse Colegiado, não é formada por indícios esparsos, mas por um conjunto consistente de indícios convergentes. A toda evidência, a possibilidade de a infração ter ocorrido não autoriza a condenação²¹. Os poucos elementos trazidos pela Acusação que resistem a um exame crítico não me parecem autorizar a conclusão de que houve prática não equitativa – aliás, não parecem suficientes sequer para a Acusação, pois também estavam presentes no período de 2003-2006, quando se optou por uma imputação menos gravosa.

¹⁹ É comum que as chamadas “operações de seguro” sejam realizadas para garantir ganhos para determinado investidor ou grupo de investidores. Em mais de um precedente, a prática ilícita consistia em realizar duas operações em sentidos opostos pela conta máster – p. ex. compra e venda de um determinado ativo financeiro. Mais adiante no pregão, verificava-se qual teria sido a estratégia vencedora e se fechava um *day-trade* para garantir o lucro para o investidor beneficiado, alocando a operação perdedora para um outro investidor. No entanto, a realização de operação apenas em um sentido não descaracteriza a “operação de seguro”. Nesse caso, o investidor beneficiado não tem certeza de que obterá lucro, mas sabe, de antemão, que não sofrerá prejuízos, uma vez que apenas operações vencedoras serão alocadas para a sua conta. A prática não equitativa, no caso, decorre do fato de que a conta de um investidor é utilizada para assegurar que outro investidor não correrá riscos em suas operações no mercado de valores mobiliários.

²⁰ V. p. ex. PAS CVM nº 13/2005, Dir. Rel. Otavio Yazbek, j. em 25.06.2012, e PAS CVM nº RJ2016/1465, Dir. Rel Gustavo Gonzalez, j. em 15.05.2018.

²¹ Nesse sentido, vale citar o voto do Diretor Relator Pedro Marcílio no PAS CVM nº 09/2004, j. em 20.06.2006: “A coerência e plausibilidade da teoria da acusação, no entanto, não são suficientes para sancionar a conduta de qualquer pessoa em um Estado de Direito. Faz-se necessário comprovar a teoria, não pela simples demonstração do resultado das operações ou pela demonstração de que a performance dos indiciados diminuiu substancialmente após a saída do indiciado Bernardo Clemente da sociedade para qual trabalhava, como fez a acusação, mas a partir de provas admitidas em direito. A coerência entre o resultado obtido e o *modus operandi* pressuposto pela acusação apenas demonstra a coerência de sua tese, mas não a comprova. Inexistentes esses resultados, a teoria não seria nem mesmo crível. Por esse motivo, o fato de os outros indiciados que teriam se beneficiado dessa especificação “não conforme” das ordens serem pessoas necessárias à implementação dessa especificação vai ao encontro da tese da acusação, mas também não é prova”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

65. Diante de todo o exposto, voto pela absolvição da ARX da acusação de realização de prática não equitativa.

IV. CONCLUSÃO

66. Por todo o exposto, com fundamento no artigo 11 da Lei nº 6.385/1976, voto:

- i. pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva da CVM no que se refere aos fatos praticados entre 2003 a 30.12.2005;
- ii. pela condenação da ARX à penalidade de advertência por ausência de critério de rateio equitativo de ordens de compra e venda dentre os diversos fundos sob sua gestão no período entre 31.12.2005 e 31.12.2006, prevista no artigo 14, II, da Instrução CVM nº 306/1999 e no artigo 60, parágrafo único, da Instrução CVM nº 409/2004;
- iii. pela absolvição da ARX da acusação de infração ao artigo 65-A, I, da Instrução CVM nº 409/2004;
- iv. pela absolvição da ARX da imputação de prática não equitativa, definida no item II, letra “d”, da Instrução CVM nº 08/1979 e vedada pelo item I da mencionada Instrução;
- v. pela condenação de Carlos Ramos à penalidade de advertência por não ter empregado o devido cuidado e diligência em promover a implantação de sistemas de controles internos que assegurassem o atendimento da regulação em vigor, especialmente no que se refere aos critérios de rateio de ordens, em violação ao artigo 14, II, da Instrução CVM nº 306/1999 e ao artigo 60, parágrafo único, c/c artigo 65-A, I, ambos da Instrução CVM nº 409/2004;
- vi. pela absolvição de BNY Mellon da acusação de violação ao artigo 65, XV, c/c artigo 65-A, I, ambos da Instrução CVM nº 409/2004; e
- vii. pela absolvição de José Carlos Lopes da acusação de violação ao artigo 65, XV, c/c artigo 65-A, I, ambos da Instrução CVM nº 409/2004.

É como voto.

Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2019

Gustavo Machado Gonzalez

Diretor Relator



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 05/2012

Reg. Col. nº 0342/2016

Acusados: ARX Capital Management Ltda.
Carlos Eduardo Teixeira Ramos
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
José Carlos Lopes Xavier de Oliveira

Assunto: Apurar eventuais irregularidades envolvendo negócios efetuados por fundos de investimentos geridos pela ARX Capital Management Ltda.

Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

VOTO-VISTA

I. BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO

1. Trata-se de processo administrativo sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Processos Sancionadores (“SPS” ou “Acusação”) para apurar eventuais irregularidades envolvendo negócios efetuados por fundos de investimentos geridos pela ARX Capital Management Ltda. (“ARX” ou “Gestora”).
2. Após efetuar suas diligências, a SPS concluiu que a ARX valeu-se da prerrogativa de realizar as especificações dos comitentes finais após o encerramento do pregão sem ter estabelecido critério prévio e equitativo de rateio sobre as ordens de compra e venda de valores mobiliários emitidas para os fundos sob a sua gestão, em infração ao artigo 14, II, da Instrução CVM nº 306/1999 e ao artigo 60, parágrafo único, combinado com o artigo 65-A, I, da Instrução CVM nº 409/2004. Além disso, o descumprimento da referida regra operacional teria permitido a Gestora, no entender da Acusação, distribuir os melhores negócios envolvendo contratos futuros de Índice Bovespa (IND) para determinados fundos em detrimento da carteira de investimentos de um fundo específico, a caracterizar prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, conduta definida no item II, “d”, da Instrução CVM nº 08/1979 e vedada pelo item I da mencionada Instrução.
3. Com relação ao diretor responsável pela atividade de gestão das carteiras de valores mobiliários da ARX, Carlos Eduardo Teixeira Ramos (“Carlos Ramos”), a SPS concluiu que o



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

acusado não teria empregado o devido cuidado e diligência na gestão dos fundos por não ter estabelecido critério equitativo e preestabelecido para ratear as ordens emitidas em nome dos diversos fundos sob a gestão da ARX, em infração ao artigo 14, II, da Instrução CVM nº 306/1999 e ao artigo 60, parágrafo único, combinado com o artigo 65-A, I, da Instrução CVM nº 409/2004.

4. A administradora dos fundos, BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (“BNY Mellon” ou “Administrador Fiduciário”), e o seu diretor responsável pela atividade de administração fiduciária de fundos de investimento, José Carlos Lopes Xavier de Oliveira (“José Carlos Lopes”), foram acusados pela SPS de infringir o artigo 65, XV, combinado com o artigo 65-A, I, da Instrução CVM nº 409/2004, uma vez que não teriam observado o dever de fiscalização dos atos praticados pela Gestora, faltando, assim, com o dever de diligência esperado às circunstâncias.

5. Iniciado o julgamento do processo em 27 de agosto de 2019, o Ilustre Diretor Relator Gustavo Gonzalez concluiu pela: (i) condenação da ARX e de seu diretor responsável Carlos Teixeira à penalidade de advertência por ausência de critério de rateio equitativo de ordens de compra e venda de valores mobiliários; (ii) absolvição da ARX da imputação de prática não equitativa; e (iii) absolvição de BNY Mellon e de seu diretor responsável José Carlos Lopes por falta de diligência na fiscalização dos atos praticados pela Gestora.

6. Naquela oportunidade, pedi vistas do presente processo para melhor examinar os elementos de prova contidos nos autos, notadamente as peculiaridades da acusação formulada pela SPS relativa à suposta prática não equitativa.

7. Após analisar detidamente os documentos constantes do processo, compartilho das conclusões do Relator no tocante às absolvições dos acusados BNY Mellon e José Carlos Lopes e às condenações dos acusados ARX e Carlos Ramos. No entanto, diverjo, respeitosamente, da penalidade de advertência aplicada a estes acusados, pois ela não é proporcional à gravidade de conduta irregular comprovada nos autos, motivo pelo qual voto pela aplicação de multa pecuniária aos referidos acusados. Também formo convicção diversa em relação ao conjunto fático-probatório constante dos autos em relação à acusação de prática não equitativa formulada pela SPS em desfavor da ARX, pois, pelas razões que passo a expor, tenho por configurada a infração de que trata a Instrução CVM nº 08/1979.

8. Antes de revelar as razões de minha divergência, entendo importante fazer algumas considerações quanto à ausência de critério de rateio equitativo de ordens e à atuação de Carlos Teixeira na qualidade de diretor responsável pela ARX junto a esta Comissão.

II. DA AUSÊNCIA DE CRITÉRIO DE RATEIO EQUITATIVO DE ORDENS DE COMPRA E VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS

9. Acompanho as fundamentadas razões do Relator no sentido de que a ARX não foi capaz de comprovar a existência de um sistema de rateio de ordens com critérios equitativos e preestabelecidos que permitisse o grupamento das ordens emitidas para os diversos fundos sob a



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

sua gestão. Neste sentido, restou incontroverso¹ que ordens de compra e venda de IND foram realizadas de forma agrupada, em nome de uma única conta máster mantida pela ARX no intermediário, cuja distribuição das quantidades e preços dos contratos negociados para cada fundo de investimento ocorria após o encerramento do pregão.

10. Evidentemente que a ARX Strike poderia usar, na qualidade de gestora profissional de investimentos, a prerrogativa normativa de especificar os comitentes dos contratos após o encerramento do pregão. Todavia, ao decidir optar por esse procedimento operacional, a Gestora tinha o ônus de possuir sistema de rateio de ordens com critérios equitativos e preestabelecidos para justificar as especificações finais tomadas em nome dos diversos fundos por ela geridos, o qual deveria ser passível de posterior verificação das decisões de alocação tomadas pelo prazo mínimo de cinco anos.

11. E, apesar de ter feito uso da mencionada prerrogativa, a Gestora não foi capaz de comprovar a existência de um sistema de rateio apto a justificar a distribuição das operações realizadas ao final do pregão². Deste modo, a ARX não estabeleceu mecanismo capaz de assegurar a regular e equitativa distribuição dos negócios realizados para as cinco famílias de fundos existentes à época, a partir de uma mesma conta master, motivo pelo qual deve ser responsabilizada por infração ao artigo 14, II, da Instrução CVM nº 306/1999, e ao artigo 60, parágrafo único, da Instrução CVM nº 409/2004.

12. O diretor responsável para dar cumprimento às regras desta Comissão no âmbito da ARX, Carlos Ramos, embora tenha alegado que cada família de fundos tinha um critério pré-definido para rateio de ordens, do mesmo modo não foi capaz de demonstrar o uso de tal critério dentro de cada família, bem como não logrou explicar a razão pela qual as ordens de um fundo que não participava de uma família foram emitidas também por meio da conta master, ou seja, de forma agrupada.

13. Como já tive a oportunidade de ressaltar em votos precedentes, a criação de centros de imputação de responsabilidade é estratégia regulatória adotada pela CVM amplamente conhecida do mercado e sufragada de forma uníssona pela jurisprudência³ administrativa da Autarquia. Seu objetivo é evitar a diluição da responsabilidade no âmbito da pessoa jurídica e estimular a adoção

¹ Nas palavras do Relator: “a ARX reconhece que, durante o período em análise, concentrava as posições dos fundos que geria e que operaram índices futuros em uma conta máster. Segundo a Gestora, a prática buscava maior eficiência operacional, ao reduzir os custos de corretagem – o intermediário, no caso, era um discount broker – e centralizar a liquidação, facilitando a centralização das margens”.

² De acordo com o relatório da Acusação, 97,3% das ordens emitidas em nome dos fundos geridos pela ARX no ano de 2007 foram especificadas após às 18h00, ou seja, a definição do comitente final foi realizada após o término do pregão. É certo que, neste momento, já eram conhecidos os valores de ajustes do dia para cada negócio realizado.

³ PAS CVM nº RJ2010/9129, Dir. Rel. Otávio Yazbek, jul. em 09.08.2011; PAS CVM nº RJ2010/13301, Dir. Rel. Luciana Dias, jul. em 23.10.2012; PAS CVM nº 08/2004, Dir. Rel. Luciana Dias, jul. em 06.12.2012; PAS CVM nº 03/2009, Dir. Rel. Ana Novaes, jul. em 30.04.2013; PAS CVM nº 01/2010, Dir. Rel. Roberto Tadeu, jul. em 09.07.2013; PAS CVM nº RJ2012/12201, Dir. Rel. Luciana Dias, jul. em 04.08.2015; PAS CVM nº RJ2013/5456, Dir. Rel. Roberto Tadeu, jul. em 20.10.2015; PAS CVM nº 12/2013, Dir. Rel. Gustavo Borba, jul. em 24.05.2016; PAS CVM nº RJ2016/6284, Dir. Rel. Pablo Renteria, jul. em 23.10.2018; PAS CVM nº 21/2010, Dir. Rel. Carlos Rebelo, jul. em 15.10.2019.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

de conduta diligente pelos administradores designados para ocupar certas funções, atribuindo-se a estes últimos a responsabilidade pelo cumprimento e fiscalização das normas legais e regulamentares⁴.

14. Nesse sentido, é o paradigma firmado no julgamento do PAS CVM nº RJ2010/9129, que trata da responsabilidade do diretor indicado pelo administrador de carteira pessoa jurídica como responsável perante a CVM, nos termos do art. 7º da Instrução CVM nº 306/99. Naquela assentada, asseverou-se:

[a] lógica de se estabelecer focos de responsabilização – diretores responsáveis por atividades específicas – é a de criar não apenas centros de imputação de responsabilidades, de modo que estas não fiquem sempre diluídas na pessoa jurídica, mas, também a de, com isso, criar estímulos para a conduta diligente – ou protetiva – dos administradores designados para aquelas funções.

Assim, ainda que uma determinada instituição sempre tenha adotado más práticas, de maneira generalizada, **cabe ao diretor responsável registrar seus esforços, tomar medidas hábeis tanto a resolver os problemas existentes, quanto a delimitar sua responsabilidade.** E isso, vale dizer, é um dos elementos a diferenciar a responsabilidade de que aqui se está tratando de responsabilidade objetiva. Também não é de inversão do ônus da prova que se trata no presente caso, uma vez que a situação, de flagrante irregularidade, restou também comprovada.

Não há que se falar em injustiça, então, na atribuição de responsabilidade a uma única pessoa no caso vertente, mas, sim, no fruto de uma estratégia regulatória que sempre foi clara. E não há que se falar também, a meu ver, que, em casos como este, a responsabilidade deva caber, de forma exclusiva, à instituição administradora (...) (grifou-se)

15. Na mesma linha, mas ainda sem a construção teórica consolidada dos “centros de imputação de responsabilidade”, é a manifestação da então Diretora Relatora Maria Helena de Santana no PAS CVM nº RJ2005/8510:

como diretor responsável, pessoa que existe na regulamentação exatamente para assegurar em nome da pessoa jurídica, que evidentemente não tem vontades, que as normas aplicáveis sejam por ela respeitadas, o diretor responsável só poderia ser eximido de culpa no caso em que ficasse demonstrado que ele tomou cuidados e providências para garantir o cumprimento dessas obrigações, que apesar de sua atuação não teriam sido seguidas.

16. Assim, à luz dos precedentes desta CVM, deveria Carlos Ramos ter demonstrado de que forma desincumbiu-se de suas responsabilidades, supervisionou com diligência ou promoveu esforços razoáveis para assegurar o cumprimento das normas estabelecidas pela CVM.

⁴ PAS CVM 19957.0003266/2017-90, Dir. Rel. Gustavo Borba, julg. em 10.04.2018.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

17. É consabido que a regulamentação da atividade de administração de carteira de valores mobiliários não apenas define os parâmetros que deverão ser fielmente observados pelas entidades que a desempenham, como também delas exige, com vistas à efetivação dos comandos normativos, a criação de mecanismos que garantam, por meio de controles internos, o permanente atendimento à legislação vigente⁵, que, no presente caso, dizia respeito à implementação de um sistema equitativo de rateio de ordens para os fundos sob gestão da ARX, o que claramente o acusado não logrou comprovar.

18. Assim, diante da inexistência de um sistema que efetivamente possibilitasse o rateio equitativo das ordens emitidas por meio da conta master em nome dos fundos geridos pela ARX, tenho que Carlos Ramos violou o artigo 14, II, da Instrução CVM nº 306/1999 e o artigo 60, parágrafo único, c/c artigo 65-A, I, ambos da Instrução CVM nº 409/2004.

19. Na dosimetria da pena, levarei em consideração, de um lado, os bons antecedentes dos acusados e, de outro, a) a natureza grave das infrações, nos termos do art. 18 da Instrução CVM nº 306/1999 e do 117 da Instrução CVM nº 409/2004, b) a prática da conduta por longo período de tempo, de 2003 a 2006, e c) a expressividade dos valores envolvidos.

III. PRÁTICA NÃO EQUITATIVA

20. A principal irregularidade apurada por meio do presente processo é a de que ARX teria direcionado, no momento da especificação das operações, os melhores negócios envolvendo contratos de IND para determinados fundos em detrimento da carteira de investimento do ARX Strike Fundo de Investimento Multimercado (“ARX Strike”), fundo exclusivo do clube de investimento dos empregados da Companhia Vale do Rio Doce (“Investvale”). Segundo a SPS, a prática adotada no âmbito da Gestora configuraria prática não equitativa vedada pelo item I e conceituada pelo item II, “d”, da Instrução CVM nº 08/79, *in verbis*:

I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não equitativas.

II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como:

(...)

d) prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, aquela de que resulte, direta ou indiretamente, efetiva ou potencialmente, um tratamento para qualquer das partes, em negociações com valores mobiliários, que a coloque em uma indevida posição de desequilíbrio ou desigualdade em face dos demais participantes da operação.

⁵ Nos termos do que dispõe o parágrafo único do art. 14 da Instrução CVM nº 306/99.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

21. Como se observa, a configuração do referido ilícito pressupõe uma ação ou omissão que possa resultar para qualquer uma das partes envolvidas em negociações com valores mobiliários indevida posição de desigualdade em face dos demais participantes da operação.

22. A importância da vedação à prática não equitativa para o funcionamento eficiente do mercado de valores mobiliários já foi destacada por este Colegiado, cabendo mencionar, neste particular, o voto condutor do Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, proferido no âmbito do julgamento do PAS CVM nº05/1999, de 23.11.2000, cujo excerto reproduzo a seguir:

O risco existe para o mercado, como em um jogo. Mas, em todo jogo, mesmo o mais arriscado, há regras, que devem ser cumpridas. Se as regras são iguais para todos, tem-se um mercado equitativo. Mas, quando, por exemplo, as cartas de um jogo vêm a ser marcadas, aí se configura uma situação não equitativa, muito diferente do risco que o jogo traz em si. Lucros e perdas são normais, desde que não provocados artificialmente, por manobras ardilosas, nem pela quebra do equilíbrio entre as partes.

23. Uma das possíveis situações que se afigura ilícita à luz do que dispõe o mencionado dispositivo é aquela em que os agentes realizam negociações denominadas “operações com seguro”, isto é, operações de compra e venda de valores mobiliários que são distribuídas a fim de produzir lucros para determinados investidores e prejuízos para outros, notadamente entidades de previdência complementar. Estas entidades assumem, com isso, o risco da variação do preço do ativo, funcionando como “seguradores” dos investidores beneficiados pelo esquema, o que caracteriza um claro desequilíbrio entre os participantes envolvidos, sendo esta justamente a prática irregular que o referido dispositivo busca coibir.

24. No presente caso, compartilho, primeiramente, do entendimento do Relator segundo o qual as provas estatísticas têm especial relevância na formação da convicção do julgador a respeito da ocorrência ou não de determinado fato, mas elas não são suficientes para amparar, *per si*, uma condenação. Do mesmo modo, registro, também em linha com o Relator, que as áreas técnicas desta Comissão devem ter cautela na realização de experimentos estatísticos, bem como cuidado nas conclusões extraídas a partir desses experimentos em casos que tais.

25. Compulsando os autos, temos, de um lado, uma sofisticação dos experimentos estatísticos realizados pela SPS para comprovar o direcionamento das ordens em desfavor da ARX Strike, e, de outro, o esforço da defesa para afastar, por meio de bem fundamentado parecer estatístico, as premissas utilizadas pela Acusação e suas correspondentes conclusões.

26. Sobre o tema, cabe, de plano, afastar as alegações da defesa no tocante ao suposto erro amostral cometido pela SPS. Ressalto, neste particular, que a metodologia amostral foi utilizada no presente processo para selecionar algumas operações realizadas pelos diversos fundos, a fim de se verificar, de forma detalhada, como as ordens emitidas pela ARX foram registradas e, ao final, especificadas. E, como já examinado, referida amostragem foi destacadamente capaz de ilustrar,

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

com nitidez, o passo a passo do procedimento operacional utilizado no âmbito da ARX, o qual se revelou irregular à luz da legislação de regência.

27. A par disso, embora seja possível identificar excesso de importância dado pela Acusação às suas conclusões estatísticas, forçoso reconhecer que, mesmo desconsiderando as probabilidades descritas pela Acusação, a SPS produziu conjunto probatório idôneo e suficiente para demonstrar que a ARX colocou o fundo ARX Strike em situação bastante desfavorável em relação aos demais fundos sob a sua gestão.

28. A primeira evidência, neste sentido, emerge da constatação de que, num mesmo intervalo de tempo (ano de 2007), determinados fundos obtêm lucros em ajustes do dia na negociação de contratos de IND, enquanto a carteira do fundo ARX Strike suporta elevados prejuízos na negociação do mesmo contrato. Quanto ao desequilíbrio da alocação das operações, convém reproduzir tabela⁶ com a soma dos ajustes do dia envolvendo a negociação de contratos de IND de cada fundo sob a gestão discricionária da ARX em 2007:

Fundo	Compras	Vendas	Ajustes do Dia (R\$)
ARX EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	16.967	18.317	3.548.232,00
ARX FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	1.432	1.432	(485.767,00)
ARX HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	252	256	191.988,00
ARX INSTITUCIONAL FIF	258	303	66.950,00
ARX LONG AND SHORT 30 FIM	12.184	11.864	570.319,00
ARX LONG AND SHORT FDO DE INV.MULTIMERCADO	11.057	10.667	416.537,00
ARX LONG SHORT 30 PF FIM	1.640	1.542	134.675,00
ARX PLUS FDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.289	2.553	762.483,00
ARX PLUS MAX FIM	10	12	6.754,00
ARX STRIKE FIM	11.475	10.625	(6.795.100,00)
BIARRITZ LLC	7.626	8.287	886.646,00
ESPECIAL 4 FIM	129	310	53.948,00
ESPECIAL 5 FIM	420	470	149.812,00
ESPECIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	2.536	2.579	101.319,00
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO ANDES	592	317	75.208,00
M195 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.286	822	148.401,00
M215 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.317	745	150.995,00
MATCH POINT INVESTMENT LLC	2.980	3.175	611.281,00
MATCH POINT INVESTMENTS LLC	5.309	5.187	2.499.320,00
Total geral	79.759	79.463	3.094.001,00

29. Como se observa, o resultado negativo do ARX Strike na negociação de IND é ruinoso em relação aos demais fundos analisados pela SPS. E, a despeito de o ARX FIA também ter

⁶ Item 58 do relatório de inquérito.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

apurado prejuízo em ajustes do dia no mercado futuro de IND, verifica-se que as perdas incorridas por esses dois fundos foram bastante distintas, uma vez que o resultado negativo do ARX Strike superou em 13 vezes o prejuízo sofrido pelo ARX FIA.

30. Ademais, a Acusação demonstrou que, nos pregões em que a ARX obteve os maiores prejuízos em ajustes do dia, tais prejuízos concentraram-se na carteira de investimentos do ARX Strike. Com efeito, dos 221 pregões do ano de 2007 em que foram registradas operações dos 19 fundos, em apenas 38 dias foram registrados negócios do ARX Strike. No entanto, nos 10 dias de maior prejuízo da conta master da ARX negociando contratos de IND, o ARX Strike operou em 9 deles. E, dos 12.224 contratos negociados pelos 19 fundos nestes dias, cerca de 65% foram especificados em nome do ARX Strike, o que representou 92,7% do prejuízo total. O prejuízo acumulado pelo ARX Strike apenas nesses dias é praticamente igual ao prejuízo total do fundo no ano de 2007, conforme ilustra a tabela⁷ a seguir reproduzida:

Comitente	Contratos		Resultado	
	quantidade	%	(R\$)	%
ARX Strike	7.900	64,5%	(6.839.000,00)	92,7%
Outros 18 fundos	4.344	35,5%	(540.740,00)	7,3%
Total	12.244	100,0%	(7.379.740,00)	100,0%

31. Ainda analisando os dados relativos aos 10 piores dias de negociação da conta master da ARX em 2007, a Acusação consignou que, em 7 dos 9 dias em que o ARX Strike operou, **houve a especificação de 100% dos contratos com ajuste do dia negativo para o fundo**. Ademais, em 2 pregões, os prejuízos do ARX Strike superaram inclusive os prejuízos da própria conta master, uma vez que nesses dias as operações com ajustes positivos foram especificadas apenas para os demais fundos, conforme revela a tabela⁸ a seguir:

Data	Prejuízo total (R\$)	Prejuízo ARX Strike (R\$)	Resultado ARX Strike / Total
28/11/2007	(1.235.200,00)	(1.235.200,00)	100%
12/11/2007	(1.066.700,00)	(1.066.700,00)	100%
05/01/2007	(1.040.370,00)	(619.200,00)	60%
14/11/2007	(762.800,00)	(896.800,00)	118%
21/11/2007	(705.300,00)	(705.300,00)	100%
13/09/2007	(578.300,00)	(528.850,00)	91%
05/10/2007	(551.600,00)	(551.600,00)	100%
18/01/2007	(535.120,00)	(776.850,00)	145%
18/09/2007	(458.500,00)	(458.500,00)	100%
17/10/2007	(445.850,00)	0,00	0%

⁷ Item 68 do relatório de inquérito.

⁸ Item 70 do relatório de inquérito.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

32. A ocorrência desses resultados é, sem sombra de dúvidas, mais um forte indicio de que a carteira do ARX Strike funcionava como um “seguro” para os dias de alta volatilidade do mercado, quando havia maior probabilidade de a Gestora não conseguir comprar e vender pelos preços inicialmente pretendidos.

33. Neste ponto, cabe afastar o argumento da defesa de que essas operações teriam esteio em “estratégia contra cíclica”⁹ adotada pela ARX na gestão da carteira do ARX Strike. Ainda que o ARX Strike tivesse bastante flexibilidade para negociar no mercado de valores mobiliários, uma vez que sua política de investimento previa “*investir em títulos e valores mobiliários de alta volatilidade, que potencializam tanto o lucro como a perda, podendo gerar, inclusive, perdas temporais do patrimônio*”, investir em ativos voláteis é bastante distinto de negociar em dias de alta volatilidade.

34. Como se sabe, é bastante difícil saber antecipadamente se determinado pregão terá ou não alta volatilidade. Ainda que os agentes de mercado possam intuir tal aspecto, somente no final do pregão a medida de volatilidade pode ser, de fato, conhecida. Ademais, muitos dos eventos que causam maior variação nos preços dos ativos negociados em bolsa ocorrem justamente durante o pregão, sendo, por isso, bastante difícil prever tal movimento.

35. Além disso, o acusado não apresentou nenhum método de controle de risco que pudesse justificar a alegada “estratégia contra cíclica” consistente em negociar contratos de IND somente em dias de alta volatilidade do mercado, ou seja, não foi trazido aos autos nenhum modelo teórico referencial que pudesse minimamente prever os momentos nos quais o ARX Strike deveria comprar, vender ou manter contratos de IND, de sorte a perseguir ventilada estratégia.

36. Tenho, aliás, que a explicação dada para respaldar as operações flagrantemente desvantajosas para o ARX Strike é bastante simplória para ser prestada por uma Gestora profissional, com registro nesta Comissão, o que denota que tal explicação é uma tentativa de dissimular a verdadeira razão para a ocorrência daquelas operações.

37. Deste modo, o fato de o ARX Strike ter negociado nos dias de maior volatilidade do mercado, sem seguir uma estratégia minimamente definida e passível de verificação posterior das decisões tomadas, justamente quando foram constatados os maiores prejuízos na conta master da ARX, demonstra que sua carteira foi indevidamente utilizada, nestes momentos, para amortecer perdas que deveriam ter sido também suportadas pelos demais fundos, mas foram dolosamente atribuídas ao ARX Strike.

⁹ Nas palavras da defesa, “*em comprar quando a bolsa está caindo e que, em regra, a existência do chamado momentum nos preços de ativos faz com que, ao longo de um dia, o preço caia (ou suba) ainda mais, sendo impossível saber o ponto mais baixo dessa queda, é comum a ocorrência de fortes ajustes do dia negativos em carteiras que utilizam a estratégia contra cíclica, sendo essa a simples explicação para os fatos que a acusação resolveu tratar como irregulares*”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

38. Melhor sorte não merece o argumento de que a rentabilidade positiva da Cartinvest¹⁰ representaria um contra indício suficiente para desviar o olhar dos demais elementos de prova que conduzem a conclusão quanto à ocorrência da prática não equitativa. De acordo com a estratégia direcional de investimentos *long-only* definida em sua política de investimento, a Cartinvest mantinha destacado volume de recursos em ações para apostar na alta de suas cotações, enquanto o ARX Strike dispunha de apenas R\$98 milhões para realizar sua política de investimentos. E, como o índice Bovespa encerrou o ano de 2007 com alta acumulada de 43,7%¹¹, era perfeitamente esperado que, mesmo com os prejuízos sofridos pelo ARX Strike, dada a sua participação inferior, a Cartinvest apresentasse, em seu conjunto, rentabilidade positiva, como de fato ocorreu.

39. Quanto à motivação da ARX para agir contrariamente à legislação, cabe destacar que essas operações são consideradas ilícitas independentemente de resultarem em vantagem financeira para aqueles que a praticaram, pois o que a norma busca evitar é que determinados agentes sejam colocados indevidamente em posição de desequilíbrio em relação a outros investidores na negociação de valores mobiliários, conforme já mencionado neste voto. Além disso, a análise dos precedentes do Colegiado da CVM acerca da matéria demonstra que não há um conjunto de elementos pré-definidos que deverão necessariamente estar presentes para caracterizar a ocorrência de “operações com seguro”¹², variando conforme as peculiaridades do caso concreto.

40. Assim, embora não se tenha identificado um beneficiário específico para as operações desvantajosas especificadas para o ARX Strike, importante registrar que os demais fundos geridos pela ARX, em especial os fundos abertos, com um número expressivo de cotistas, obtiveram lucros na negociação de contratos de IND no período objeto da investigação, tendo, por isso, beneficiado-se do ilícito.

41. Noto, ademais, que, diferentemente de outros casos de práticas não equitativas em que normalmente é difícil compreender a relação de todos os investidores envolvidos no esquema irregular, o presente processo tem a peculiaridade de ocorrer dentro da mesma Gestora, com as operações realizadas por meio da mesma conta master, mantida no mesmo intermediário, cujo controle dos comitentes finais e das quantidades negociadas era efetuado após o encerramento do pregão e sem a utilização de qualquer critério prévio e equitativo de alocação das operações, tendo um fundo sido colocado em posição de desequilíbrio em relação aos demais.

¹⁰ Cartinvest é a designação dada pela ARX Capital para a estratégia de investimento aplicável aos ativos da Investvale, que incluem carteira própria e o Fundo ARX Strike.

¹¹ <<https://oglobo.globo.com/economia/bovespa-encerra-2007-com-alta-acumulada-de-437-4131313>>, acessado em 04.11.2019.

¹² Nesse sentido, no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM nº 21/06, julgado em 07.08.2012, a Diretora Relatora Ana Novaes asseverou que “(...), mais do que parâmetros pré-definidos, este Colegiado já consolidou reiteradas vezes ‘o entendimento de que a presença de indícios variados e convergentes é suficiente para a formulação de uma peça acusatória e, eventualmente, de uma condenação’”. No mesmo sentido, ver PAS CVM nº 06/2012, julgado em 20.08.2008.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

42. Todos esses fatos devidamente comprovados nestes autos levam à minha convocação de que, na realidade, a concentração de prejuízos em nome do ARX Strike não foi fruto da alegada “estratégia contra cíclica” adotada pela ARX, mas sim da utilização indevida do fundo como anteparo das operações, com destacado ajuste do dia negativo, realizadas pela ARX em dias de alta volatilidade. Por tais razões, o ARX Strike foi colocado em condição de desequilíbrio em relação aos demais, a caracterizar prática não equitativa vedada pela regulamentação desta Comissão, motivo pelo qual voto pela responsabilidade da ARX no presente caso.

43. Na dosimetria da pena, levarei em consideração, de um lado, os bons antecedentes do acusado e, de outro, a) a natureza grave da prática não equitativa prevista no item II, alínea “d”, da Instrução CVM nº 08/1979 e vedada pelo seu item I, b) a prática reiterada da conduta; e c) o elevado prejuízo causado ao fundo.

IV. CONCLUSÃO

44. Por todo o exposto, divirjo parcialmente do voto do Diretor Relator e, com fundamento no art. 11, II, da Lei nº 6.385/76, voto:

- (i) pela condenação da ARX à penalidade de R\$100.000,00 (cem mil reais) por ausência de critério de rateio equitativo de ordens de compra e venda dentre os diversos fundos sob sua gestão no período entre 31.12.2005 e 31.12.2006, prevista no artigo 14, II, da Instrução CVM nº 306/1999 e no artigo 60, parágrafo único, da Instrução CVM nº 409/2004;
- (ii) pela condenação de Carlos Teixeira à penalidade de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais) por não ter promovido a implantação de sistemas de controles internos que assegurassem o atendimento da regulação em vigor, especialmente no que se refere aos critérios de rateio de ordens, em violação ao artigo 14, II, da Instrução CVM nº 306/1999 e ao artigo 60, parágrafo único, c/c artigo 65-A, I, ambos da Instrução CVM nº 409/2004; e
- (iii) pela condenação da ARX à penalidade de R\$400.000,00 (quatrocentos mil reais) pela prática não equitativa, conforme conduta definida no item II, letra “d”, da Instrução CVM nº 08/1979 e vedada pelo item I da mencionada Instrução.

É como voto.

Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 2019

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR